

노동관행과 신뢰책임에 관한 고찰

동아대학교 법과대학 강사·법학박사 정 명 현

논문요지

단체협약, 취업규칙, 근로계약 등에 명시적인 규정이 없어 근로계약의 내용을 명확히 확정 지을 수 없는 경우에 노동관행은 실제 당해 부분사회의 규범이 되어 근로조건을 규율하는 매우 중요한 역할을 한다. 노동관행은 근로자 집단에 관계되는 것일 수도 있고 개별 근로자에 관계되는 것일 수도 있으며 그에 따라 그 법적 성질이 다를 수 있다고 본다. 근로자 집단에 관계되는 노동관행은 기업의 질서와 관계된 규범으로서 취업규칙과 유사한 성격을 가진다고 하겠으며 개별 근로자에 관계되는 노동관행은 근로계약과 유사한 성격을 가진다고 본다. 노동관행의 성립요건으로서 계속성·반복성은 모든 법률행위에 있어서 확일적으로 정해질 수는 없다고 본다. 노동관행은 관습법적 지위에 있을 수도 있고 규범적 지위, 계약적 지위, 사실인 관습적 지위, 사실인 관습에 이르지 못한 지위에 있을 수 있다. 우리나라 대법원은 규범과 동등한 정도이거나 사실인 관습과 묵시적 합의를 갖춘 노동관행에 대하여 법적 구속력을 인정하고 있다고 하겠다. 노동관행이 인정되면 전부를 얻고 그렇지 못하면 전부를 잃는 등 노동관행의 인정과 관련하여 존재하는 불합리한 점을 보완하는 방법으로 신뢰책임을 원용할 수 있을 것이라고 본다. 관행이 성립하지 않아도 신뢰책임은 성립할 수 있을 것이기 때문이다. 신뢰책임을 성립하면 신뢰의 크기에 비례한 이행책임 또는 손해배상책임을 물을 수 있어, 전부를 잃거나 아니면 전부를 얻는 식이 아닌, 절충적인 원만한 해결에 기여할 수 있다. 신뢰책임을 노동관행의 성립과 병존할 수 있으나 노동관행이 성립하면 신뢰책임을 원용할 실익이 없어진다. 따라서 노동관행이 규범이나 계약으로서의 법적 지위를 인정받지 못할 때 신뢰책임을 원용할 수 있다고 본다. 신뢰의 크기에 비례한 책임부담의 원칙을 적용한다면 당사자들이 느끼는 권리 대비 책임의 크기 간의 괴리를 줄이고 쌍방의 만족감을 증대시킬 수 있을 것이라고 본다.

주제어 : 관행, 노동관행, 신뢰책임, 관습법, 사실인 관습

* 원고접수: 2013. 10. 1. 심사완료: 2013. 11. 12. 게재확정: 2013. 11. 22.

I. 들어가며

단체협약, 취업규칙, 근로계약 등에 명시적인 규정이 없어 근로계약의 내용을 명확히 확정 지을 수 없는 경우에 노동관행은 실제 당해 부분사회의 규범이 되어 근로조건을 규율하는 매우 중요한 역할을 한다. 노동관행이 근로조건을 규율하는 효력을 가진다고 할 때 노동관행의 법적 성질을 규범이라고 보아야 할 것인지 계약으로 보아야 할 것인지 견해의 대립이 있다. 어떤 행위가 관행으로서의 법적 지위를 인정받느냐의 여부에 따라 법적 구속력이 좌우되므로 관행의 성립요건은 중요하다. 관행의 성립요건으로 계속성·반복성을 들지만 그 요건 충족여부에 대한 판단은 쉽지 않고 충족여부를 일도양단으로 구분하는 방식은 권리의 전부를 잃거나 아니면 전부를 얻는 극단적인 결과를 낳는다. 노동관행의 성립여부에 대한 판단의 어려움과 성립여부에 따라 양당사자에 미치는 극단적인 결과는 노동관행을 둘러싼 분쟁의 해결을 어렵게 만든다. 노동관행의 성립과 관련하여 존재하는 이러한 불합리한 점을 보완하는 방법으로 신뢰책임을 원용할 수 있을 것이라고 본다. 관행이 성립하지 않아도 신뢰책임을 성립할 수 있기 때문이다. 신뢰책임이 성립하면 신뢰의 크기에 비례한 이행책임 또는 손해배상책임을 물을 수 있어, 전부를 잃거나 아니면 전부를 얻는 식이 아닌, 절충적인 방법에 의한 원만한 분쟁의 해결을 도모할 수 있다. 이러한 관점에서 노동관행과 신뢰책임의 성립요건 및 효과는 어떠한지를 각각 살펴보고 노동관행과 신뢰책임 간의 관계를 설정해 보고자 한다.¹⁾

II. 노동관행의 개념 및 법적 성질

1. 개념

‘관행’이란 사회에서 반복적으로 행하여지는 사실적 행위를 말한다. 한 사회에서 공유된 행동 양식이나 태도가 존재할 때 그것을 지배하는 규칙이라고 할 수 있다.²⁾ 행위자가

1) 본 주제와 관련한 선행연구들은 대체로 노동관행 또는 신뢰책임에 관한 것으로서 제각기 독립적으로 이루어져 왔다. 다만 노동관행의 법적 성질에 관한 학설 중의 하나인 신뢰책임설을 통하여 노동관행과 신뢰책임과의 관계가 어느 정도 설명되고 있다. 본 연구에서는 과거의 연구수준을 넘어서 노동관행과 신뢰책임과의 관계를 좀 더 깊이 있게 다루었다는 점이 특징적이라고 할 수 있다.

다른 행위자의 눈치를 보면서 규칙을 따르게 되는 것이 관행의 존재를 입증해 준다. 아는 사람과 마주칠 때 반드시 인사를 주고받아야 한다는 법은 없지만 서로 인사를 해야 한다는 부담을 가지며 인사를 하지 않을 때는 상대방에 대한 불쾌한 감정을 갖게 되는 것은 그러한 관행이 존재하기 때문이라고 할 수 있다. 관행은 미리부터 특정행위를 할 것으로 정해진 것이 아니며 임의로 선택된 규칙에 불과하다. 임의로 선택된 규칙을 따르는 이유는 다른 사람들 역시 그 임의 규칙을 따른다는 사실을 강하게 예측하고 있기 때문이다. 관행은 행위의 규칙성과 이에 대한 예측 또는 기대를 가지고 있을 것을 필요로 하며 단순히 공동체의 구성원들의 행위가 우연히 일치하는 행위들과는 구분되어야 한다.³⁾ 관행은 그 내용이 도덕적이기 때문에 따르는 것이 아니며, 상황이 변하거나 선호의 결과가 바뀌거나 관행이 의존하고 있는 공유된 경험 구조에 혼란이 발생하면 더 이상 관행은 유지되지 못하고 폐기된다.⁴⁾

노동관계에서 존재하는 관행을 ‘노동관행’이라고 한다.⁵⁾ 근로관계의 현장에서는 근로조건, 직장규율, 시설관리, 조합활동 등에 관하여 취업규칙, 단체협약, 근로계약 등의 명시적인 규정에 의하지 않고, 어떤 사실이나 행위가 노사간에 상당기간 이의 없이 반복하여 계속 행해지고, 그것이 사실상 상당한 정도로 구속력을 갖고 있는 경우 이를 노동관행이라고 하는 것이다. 단체협약, 취업규칙, 근로계약 등에 명시적인 규정이 없어 근로계약의 내용을 명확히 확정 지을 수 없는 경우에 노동관행은 실제 당해 부분사회의 규범이 되어 근로조건을 규율하는 매우 중요한 역할을 한다.⁶⁾ 이러한 노동관계에서의 현실적 관행은 근로계약의 내용을 보충하며 노사 간의 규칙으로 인식되고 문서화되어 취업규칙 또는 단체협약의 내용이 되고, 이 중 일부는 노동입법으로 진전되기도 한다.⁷⁾ 노동관행이란 개념에 대해 명확하게 정의된 바도 없고 실정법상에 규정되어 있지는 아니하나, 노동현장에서 근로조건 및 직장질서 등에 관련된 행위가 장기적·반복적·계속적으로 행하여지는 경우 노사 간의 행위준칙으로 인정된다.⁸⁾ 노동관행은 기업 내에 있어서의 관행과 초기업적 규모에 걸친 관행, 개별 근로자에 관계되는 관행과 근로자 집단에 관계되는 관행, 법령, 단

2) David Lewis, *Convention*, New York: Blackwell, 2002, p. 8.

3) Gerald J. Postema, *Coordination and Convention at Foundation of Law*, *Legal Studies* V.11, 1982, p. 177.

4) *ibid.*, p.178.

5) 노동관행이라는 용어보다는 ‘경영관행’이라는 용어를 사용하는 경우도 있다. 경영관행은 노동관행과 마찬가지로 보통 경영 내에서 동일한 형태 내지 급부가 사실적으로 반복됨으로써 그것이 청구권의 성립근거가 되는 경우에 인정된다(김형배, 노동법, 박영사, 2009, 104면).

6) 박홍규, 노동법론, 삼영사, 1998, 201면.

7) 김치선, 노동법강의, 박영사, 1997, 91면.

8) 김형배, 앞의 책, 103면; 김유성, 노동법 I, 법문사, 2005, 14면; 권오성, “노사관행의 법적 성질에 관한 일고찰”, 변호사 제34집, 서울지방변호사회(2004), 185-185면.

체협약, 취업규칙, 근로계약 등의 제규정을 보충 또는 보완하는 관행과 이들 제규정에 상충하는 관행 등으로 구별할 수 있을 것이다.⁹⁾

2. 법적 성질

(1) 학설

노동관행의 법적 성질에 관한 학설로 계약설, 규범설, 신뢰책임설 등이 있다. 계약설은 노동관행 그 자체는 특별한 법적 효력을 가지지 않지만, 근로조건에 관하여 노동관행에 따른 일정한 취급이 이의 없이 반복적으로 행하여져 온 경우 근로계약의 당사자간에 당해 노동관행의 준수에 관한 묵시의 합의가 성립된 것으로 보거나, 당사자가 ‘사실인 관습’으로 성립된 노동관행에 따를 것을 용인한 것으로 보아 당해 노동관행이 근로계약의 내용으로 편입되어 그 구속력이 인정된다고 본다.¹⁰⁾ 계약설에는 ‘묵시적 합의설’과 ‘사실인 관습설’이 있다. 묵시적 합의설은 노동관행의 구속력의 근거를 사용자가 일정한 경영상의 행위 내지 취급을 반복할 경우에는 그러한 행위 내지 취급에 대하여 의무를 부담하겠다는 사용자의 의사가 추단되고, 근로자가 이를 수령함으로써 승낙하게 된다고 하는 당사자간의 묵시적 합의에서 찾는다.¹¹⁾ 사실인 관습설은 노동관행을 하나의 기업단위에서 성립하는 ‘사실인 관습’으로 보아야 한다는 견해이다. 즉, 관습법(민법 제1조)과 사실인 관습(민법 제106조)에 관한 민법에서의 구별에 상응하여 노사관계에서의 노동관행도 관습법으로 성립된 노동관행과 사실인 관습에 해당하는 노동관행으로 구별한다. 노사관계에서는 ‘법적 확신’이 유지되는 관습법은 성립되기는 어려우므로 노동관행의 대부분은 사실인 관습에 속한다고 보는 입장이다.¹²⁾

규범설은 노동관행을 노사간의 법률관계에 직접 적용되는 법원의 일종으로 파악하는 견해이다. 이러한 규범설에는 노동관행을 단체협약이나 취업규칙 등과 나란히 독자적인 법원으로 보는 ‘규범설’, 노동관행을 불문의 취업규칙으로 보는 ‘차용법원설’, 노동관행을 경영상의 관습법의 일종으로 보아 노동관행이 법규범처럼 직접적·강행적으로 노사간의 법률관계에 적용된다는 ‘경영상 관습법설’이 있다. 규범설은 노동관행에 법적 구속력이 인정되기 위해서는 집단적 노사간에 존재하는 관행적 사실이 있고, 그 사실이 반복하여

9) 송강직 역, 노동법, 삼지원, 1995, 78면; 권오성, 위의 논문, 185면.

10) 임종률, 노동법, 박영사, 2013, 10면.

11) 하경효, 노동법사례연습, 박영사, 2002, 68면.

12) 박홍규, 앞의 책, 202면.

계속되고 있으며, 노사 쌍방의 규범의식이 추정될 수 있어야 한다는 3가지의 요건을 들고 있다.¹³⁾ 차용법원설은 노동관행에 불문의 취업규칙으로서의 성격을 부여하여 노동관행이 취업규칙 등의 기존의 법원과 동등한 법원이 된다고 본다.¹⁴⁾ 경영상 관습법설은 노동관행을 일종의 경영상의 관습법으로 파악하여 구체적인 노동관행이 마치 법규범처럼 직접적, 강행적으로 적용된다고 보는 견해이다.¹⁵⁾

신뢰책임설은 노동관행의 구속력의 근거를 노사관계의 일방 당사자가 그 상대방에게 노동관행에 의하여 계속적인 급부가 행하여질 것이라는 신뢰를 발생시킨 데 대한 신뢰책임에서 찾는 견해이다.¹⁶⁾ 일정한 관행이 기업 내에서 계속되어 온 경우에 취업규칙이나 근로계약의 내용에 반하지 않는 한 근로자들은 계속적인 급부가 행하여질 것이라는 기대이익을 가질 수 있게 되고, 사용자에게는 신뢰책임에 비추어 이러한 관행의 범위 내에서 근로자들의 청구권을 인정하여야 한다는 것이다. 다시 말하면 동일한 행위가 반복·계속되는 경우 근로자들은 앞으로도 그와 동일한 행위가 반복될 것이라는 신뢰를 하게 되고, 이러한 신뢰는 보호되어야 한다는 것이다.¹⁷⁾ 신뢰책임설은 노동관행에 의한다는 당사자의 묵시적 합의가 없는 경우에도 일정한 요건이 충족될 경우에는 노동관행의 구속력을 인정할 수 있다고 본다. 신뢰책임은 신뢰책임을 부담하는 자의 자기의사 또는 자기결정이 결여되어 있다는 점에서 법률행위책임과는 구별되며 법정행위책임이라고 할 수 있다.¹⁸⁾ 신뢰책임과 관련하여서는 뒤에서 상세히 설명하기로 한다.

(2) 판례

대법원 판례에서는, 어느 기업의 관행이 근로계약의 내용을 이루고 있다고 인정하기 위해서는 그와 같은 관행이 기업사회에서 일반적으로 근로관계를 규율하는 규범적인 사실로서 명확히 승인 되거나, 기업의 구성원이 일반적으로 아무런 이의도 제기하지 아니한 채 당연한 것으로 받아들여 기업 내에서 사실상 제도로써 확립되어 있지 않으면 안 된

13) 김재훈, “근로조건 변경의 법리-불이익변경의 한계를 중심으로”, 박사학위논문, 서울대학교 대학원(1999), 305면.

14) 현경대, “노동법의 법원에 대한 일고찰”, 국제화시대의 노동법의 과제/가산 김치선 박사 고회기념논문집(1994), 485면.

15) 하경효, 앞의 책, 68면.

16) 위의 책, 66면. 김형배 교수는 신뢰책임설이 오늘날의 지배적 학설이라고 한다(김형배, 앞의 노동법, 104면 참조).

17) Seiter, *Die Betriebsübung*, 1967, S.92ff; Canaris, *Die Vertrauenshaftung im deutschen Privatrecht*, München, 1971, S.387ff.

18) Canaris, op. cit., S. 428f.

다고 판시함으로써 노동관행이 규범과 동등한 정도에 해당하거나, 규범에 이르지 아니하더라도 노동관행에 대한 구성원들의 묵시적 합의와 사실인 관습이 존재하는 것으로 인정될 때 당해 노동관행은 근로계약의 내용을 이루고 있다고 인정하는 입장을 취하고 있는 것으로 보인다.¹⁹⁾ 이처럼 대법원은 사실인 관습으로서의 노동관행이 존재하는 경우에도 기업의 구성원이 아무런 이의를 제기하지 아니하고 당연한 것으로 받아들이는 묵시적 합의가 있는 경우에 한하여 노동관행의 구속력을 인정함으로써 구속력 있는 노동관행의 성립 가능성을 매우 좁게 인정하고 있는 편이라고 하겠다.

(3) 검토

노동관행은 근로자 집단에 관계되는 것일 수도 있고 개별 근로자에 관계되는 것일 수도 있다고 본다. 근로자 집단에 관계되는 노동관행과 개별 근로자에 관계되는 노동관행은 그 법적 성질이 다를 수 있다고 본다. 근로자 집단에 관계되는 노동관행은 근무시간 중 휴게시간의 부여방법, 출퇴근 시의 편의 제공, 성과급 배분 방식 등 전체 근로자에 적용되는 사항 등에서 존재할 수 있다. 개별 근로자에 관계되는 노동관행은 업무수행방법, 개인별 수당지급, 근무장소나 배치 등 개별 근로자에 국한하여 적용되는 사항 등에서 존재할 수 있다. 아래에서 근로자 집단에 관계되는 노동관행과 개별 근로자에 관계되는 노동관행을 구별하여 살펴본다.

다수 근로자의 근로조건을 규율하는 취업규칙의 법적 성질에 관해서 규범설과 계약설의 대립이 있다. 취업규칙을 규범으로 보는 견해에 따르면 근로자 집단에 관계되는 관행은 취업규칙과 유사하므로 그 관행을 ‘규범’으로 보게 된다. 취업규칙의 법적 성질을 계약으로 보는 견해에 따르면 취업규칙은 그 작성과 변경절차에서 근로자집단의 의견, 동의 등을 거치도록 하고 있다는 점을 들어 근본적으로 취업규칙의 법적 성질을 ‘계약’이라고 한다. 그러나 계약설에 의할 때에도 근로기준법(이하 ‘근기법’이라 한다.) 제97조의 수권에 의하여 취업규칙의 규범적 효력이 발생하기는 마찬가지다. 근로자 집단에 관계되는 관행의 법적 성질을 계약으로 보기 위해서는 근로자 집단의 의견수렴 및 동의 등이 전제되어야 한다. 개별 근로자에 관계되는 관행과는 달리, 근로자 집단에 관계되는 관행에 대한 근로자 집단의 묵시적 동의가 있었는지는 확인하기 어렵기 때문에 근로자 집단에 관계되는 관행을 곧 바로 계약으로 보는 것은 무리가 있어 보이고, 신입직원의 입사 시에 근로자 집단에 관계되는 관행이 즉시 적용되는 점 등을 고려해 보면²⁰⁾ 근로자 집단에 관계되

19) 대판 1993. 1. 26, 92다11695; 대판 1996. 5. 10., 95다42270; 대판 2002. 4. 23, 2000다50701.

는 관행의 법적 성질은 규범으로 보는 것이 적절하다고 본다.

한편 개별 근로자에 관계되는 관행의 법적 성질에 관해서도 규범설과 계약설로 의견이 나뉠 수 있다. 규범설은 개별 근로자에 관계되는 관행을 단체협약이나 취업규칙 등과 나란히 독자적인 법원으로서 파악하여 그 규범적 효력을 인정하는 것이다. 계약설은 일정한 경영상의 행태가 반복되면 그러한 행태에 대하여 장래에도 동일한 행태를 반복하겠다는 의사가 추단되거나 묵시적 의사가 인정되어 계약으로서의 효력이 발생한다고 보는 것이다. 사용자의 반복된 급부에 대하여 해당 근로자가 이의를 제기함이 없이 이를 수령하여 왔다면, 이러한 수령행위는 곧 사용자의 청약에 대한 근로자의 승낙의 의사표시를 내포하고 있는 것이라 평가할 수 있으므로 계약으로 보는 것이 적절하다고 본다.

신뢰책임설에 따르면 개별 근로자에 관계되는 관행이든, 근로자 집단에 관계되는 관행이든 묻지 않고 취업규칙이나 근로계약의 내용에 반하지 않는 한 일정한 관행이 기업 내에서 계속되어 온 경우 사용자는 신뢰책임에 근거하여 근로자들의 청구권을 인정하게 된다. 규범설에 따르면 신입사원이 입사하기 전에 이미 존재하던 경영관행의 효력이 신입사원에게도 발생한다고 보나 신뢰책임설에 의하면 신입사원의 입사 전 존재하던 경영관행은 신입사원에게 신뢰를 형성시켰다고 보기 어렵기 때문에 그 관행의 효력을 인정할 수 없게 된다. 신뢰책임설은 노사당사자의 의사가 명확하지 않은 경우에 근로관계의 내용을 형성하는 효력을 가진다는 견해인데 만약 어떤 노동관행에 묵시적 승인이 있다고 본다면 계약설에 의해 법적 효력을 주장할 수 있으므로 굳이 신뢰책임설을 원용하지 않아도 된다. 그럼에도 신뢰책임설이 유용한 이유는 신뢰책임설에 의하면 노사당사자의 의사가 명확하지 않은 경우에도 신뢰책임에 의한 법적 효력을 인정할 수 있다는 점이다. 그러나 신뢰책임설에 따를 경우에도 실질적으로 당해 관행은 이미 노사 당사자가 자기들의 노사관계를 형성하고 근로관계를 규율하고 있다는 암묵적 의사가 분명하게 존재한다고 볼 수 있다는 점, 만약 노사 당사자가 그 관행에 의하지 않았다는 의사가 표출 되었다면 그러한 관행은 파기되거나 성립되지 않았을 것이라는 점, 노동관행은 당사자간의 계약에 의하여 그 효력이 배제될 수 있다는 점 그리고 신뢰책임을 근거로 근로자에게 불리한 노동관행의 구속력을 인정하는 것은 곤란하다는 비판이 있다.

따라서 필자는 일차적으로 노동관행의 법적 성질에 관해서 근로자 집단에 관계되는 관행과 개별 근로자에 관계되는 관행으로 나누고 근로자 집단에 관계되는 노동관행은 다수 근로자의 근로조건 및 기업의 질서와 관계된 규범으로서 취업규칙과 유사한 성격을 가진

20) 만약 근로자집단에 관계되는 관행을 계약으로 보게 되면 신입직원이 입사 시에 취업규칙의 내용을 알고 근로계약을 체결하였기 때문에 취업규칙은 계약으로서 효력을 발휘한다는 논리를 내세우지만 서면화 되어 있지 않은 관행에 대해서 이를 숙지하고 근로계약을 체결하였다고 보기에는 너무 비약적이다.

다고 하겠으며 개별 근로자에 관계되는 노동관행은 근로계약과 유사한 성격을 가진다고 본다. 신뢰책임설은 규범이나 계약으로서의 법적 지위를 인정받지 못할 때 신뢰책임으로서의 법적 효력을 원용할 수 있다고 본다.

Ⅲ. 노동관행의 성립과 효력

1. 성립 요건

관행은 어떤 문제에 대해 공동체의 구성원들이 보이는 태도나 행동이 공통점을 가질 때 형성된다.²¹⁾ 단 한번 행하여진 것은 선례에 해당할 뿐 노동관행이라고 할 수는 없다. 관행의 법적 효력을 논하기에 앞서 관행으로서의 성립 여부에 대한 판단이 무엇보다 중요하다. 관행으로 인정되지 않으면 관행의 법원이나 효력 등을 논할 실익이 없기 때문이다. 어떠한 행위가 관행으로 성립하기 위해서는 관행으로서의 성립요건을 충족하여야 할 것이다. 노동관행의 성립요건으로는 동종의 행위나 사실이 장기간 계속적으로 반복되고, 당사자 간에 묵시적 합의가 있는 것으로 추정될 수 있어야 한다.

(1) 계속성·반복성

노동관행이 성립하기 위한 첫째 요건으로, 동종의 행위나 사실이 장기간 계속되거나 수회 반복될 것을 요한다. 장기간 계속 또는 수회의 반복 중 하나만 충족하면 되고 반드시 두 가지 사실을 충족시켜야 하는 것은 아니다. 장기간 계속된 행위가 노동관행으로 인정되기 위해서는 어느 정도의 기간 동안 계속되어야 하는 것인지 명확한 기준이 필요하다. 그러나 관행으로 인정받기 위한 장기간은 모든 법률행위에 있어서 확일적으로 정해질 수는 없다고 본다. 장기간 계속적 반복은 어느 정도 지속적 이어야 하는지 구체적 기준은 정할 수가 없다. 판례에서는 사용자에게 근로의 대상성이 있는 금품에 대하여 그 지급의무의 발생근거는 단체협약이나 취업규칙, 급여규정, 근로계약에 의한 것이든 그 금품의 지급이 사용자의 방침이나 관행에 따라 계속적으로 이루어져 노사간에 그 지급이

21) Jules Coleman, *Incorporationism, Conventionality and the Practical Difference Thesis*, Hart's Postscript, New York: Oxford, Press, 2001, p. 101.

당연한 것으로 여겨질 정도의 관례가 형성된 경우처럼 되어야 노동관행이라고 할 수 있다고 한다.²²⁾ 마찬가지로 몇 번의 행위가 반복되어야 노동관행으로 인정될 수 있을 건가에 대해서도 모든 법률행위에 있어서 똑 같이 확일적으로 정해질 수는 없다고 본다.²³⁾

계속성 및 반복성과 관련하여서는 ‘정도’의 문제를 논의할 필요가 있다. ‘어느 정도’ 계속되거나 반복될 때 관행으로 인정할 것인가에 대한 판단 기준도 논의의 대상이 되지만 계속성·반복성의 정도의 강약도 논의의 대상이 될 수 있다. 계속성·반복성이 처음 형성되기 시작할 시점에는 계속성·반복성의 정도가 매우 약하다고 할 수 있고 계속성·반복성이 상당히 오랜 기간, 무수히 반복된 시점에는 계속성·반복성의 정도가 매우 강하다고 할 수 있다. 계속성·반복성의 정도의 크기는 단계적이거나 단속적인 형태로 나타나는 것은 아니며 점진적·연속적으로 변화한다. 쉽게 말하면 그 정도의 크기 변화는 깔때기나 나팔 모양처럼 처음에는 좁으나 나중으로 갈수록 점점 폭이 넓어지는 것이다. 노동관행의 성립요건으로서의 계속성·반복성의 충족여부를 판단할 때는 점진적·연속적으로 변해가는 계속성·반복성의 정도를 특정 지점에서 선을 그어 한 쪽은 충족, 다른 한 쪽은 불충족으로 구분한다. 이러한 구분은 법적 개념을 정의하기 위해 인위적으로 만든 구분선에 불과하다. 이 구분선은 상당히 주관적이어서 구분하는 사람에 따라 다르며 모든 사람에게 공통된 구분 기준을 제공하지 못한다.²⁴⁾ 법원에서 재판을 통하여 과거의 판

22) 대판 1997. 5. 28. 96누15084.

23) 반복성과 관련하여서는 시기, 내용, 대상, 장소 등으로 구분해 볼 수 있고 제각기 판단기준이 다를 수 있다. 첫째, 시기적 반복성은 확일적인 인정기준보다는 해석하고자 하는 구체적인 대상과 성격에 따라 개별적으로 판단해야 할 것이다. 즉, 어떤 노동관행이 5년 정도 반복되었다고 하여도 1년 단위로 법률관계가 형성되는 것과 매일 또는 매월 성립되는 법률관계 사이에는, 법률행위주체 사이에 그러한 사실의 반복으로 형성된 기대 또는 신뢰의 보호가치는 다를 수 있기 때문이다. 둘째, 내용적 반복성으로는 야간근로시 할증수당과 퇴직금지급에 있어 근로기준법에 규정된 이상의 금전을 지급해 오던 노동관행은 반복성의 판단에서 다를 수 있다는 것이다. 전자는 근로관계가 형성되어 유지되는 동안 자주 또는 수회 반복되는 특성이 있지만, 후자는 근로관계의 종료시 1회에 한하여 발생하는 것이기 때문이다. 셋째, 반복성을 적용받는 인적 또는 장소적 기준은 해당 기업 또는 사업장을 기준으로 노동관행이 존재하는지 여부를 결정하여야 한다. 또한 특별한 사정이 없는 한 해당기업에서 근무하는 모든 근로자를 대상으로 판단해야 하겠지만, 위험직무수당처럼 그 적용대상 근로자가 부분적이라면 해당 직무에 종사하는 관련 근로자로 한정하여 노동관행의 존재여부를 판단해야 할 것이다(박수근, “노동관행의 규범성과 단체협약의 소급적 효력”, 2001노동관례비평, 민주사회를 위한 변호사모임(2002), 132면).

24) 노동관행은 노동관계를 규율하는 규범인 법원으로 인정된다고 보는 것이 일반적인 견해이다. 노동관계를 규율하는 살아있는 규범으로서의 역할을 수행하기 위해서는 노동관행의 성립여부에 대해 일반인들이 어느 정도 판단 가능할 수 있어야 한다. 사용종속관계 하에 놓인 근로자가 규범성이 확인되지 않은 노동관행에 근거하여 권리주장을 하기는 어려우며 사용자 또한 규범성이 확인되지 않은 노동관행을 준수하려고 하지 않을 것이다. 노동관행의 성립여부를 두고 이해당사자간 견해가 달라서 매년 재판을 통하여 확인될 수 있다면 노동현장의 권리규범으로서의 역할이 미미할 것이다. 따라서 구체적 사건에 있어서 각 행위 별로 노동관행이 인정될 수 있는 기준을 마련하여 노동현장에서 활용하도록 하는 것도 노동관행과 관련된 노동문제를 예방하는 하나의 방법이 될 수도 있다고 본다. 이러한 기준이 노동관계를 규율하는 재판규범으로서의 지위는 인정되지 않으나 행위규범으로서의 지위를 가지고 있으므로 분쟁을 예방하는 기능을 수행할 수 있을 것이다.

례 및 사회적 통념, 시대 상황, 사건의 구체적 내용 등을 종합·검토하여 사후적으로 그 구분선을 명확히 확정 지을 수 있겠지만 법관 또한 자신이 보는 관점에 따라 주관적으로 판단하기는 마찬가지이다.²⁵⁾ 관행적 사실이 어느 정도 계속·반복되어야 하나에 대해서는 절대적인 기준은 없고 관행의 시기와 내용 그리고 적용범위 등 구체적인 사정을 종합하여 판단해야 한다고 한다.²⁶⁾ 그러나 적어도 3회 이상은 행하여져야 할 것으로 보는 견해도 있다.²⁷⁾ 아무튼 그 기업 내에서는 사실상 제도화 되어 있다고 할 정도로 상당기간 반복될 필요는 있을 것이다.

현재, 관행의 성립요건 중 계속성·반복성 충족 여부를 이분법적으로 구분하고 있다. 특정 지점에 구분선을 그어 관행성립 또는 불성립으로 구분한다. 관행성립이 인정되면 완전한 청구권이 인정되고 관행성립이 부정되면 청구권은 전혀 인정되지 못한다. 당사자들에게는 청구권 전부를 얻느냐 전부를 잃느냐의 사생결단의 문제가 되기 때문에, 당사자 간 이해관계가 첨예하게 대립하게 된다. 대법원은 노동관행의 성립요건으로 그 관행이 기업사회에서 일반적으로 근로관계를 규율하는 규범적인 사실로서 명확히 승인되거나 기업 내에서의 사실상의 제도로서 확립되어 있음을 요구하여 노동관행의 인정에 대하여 기업이라는 부분사회의 거의 관습법 정도를 이룰 것을 요구하는, 엄격한 태도를 취하고 있는 편이다.²⁸⁾ 이는 관행에 관한 명확한 판단기준이 없는 상태에서 대법원은 가능한 관행의 명백한 징후가 표출된 것에 한하여 관행을 인정하려 하는 태도를 취하려하기 때문이다.

25) 사용자가 노동관행을 위반한 경우, 근로자가 권리구제를 받기 위해서는 먼저 해당 노동관행의 효력이 인정될 수 있어야 한다. 그러나 노동관행의 효력여부에 관한 판단은 일반인이 할 수 없고 법원을 통하여 가능하다. 따라서 노동관행의 위반행위에 대하여 근로자가 권리구제 신청을 하기 위해서는 민사소송을 제기하여야 한다. 그러나 민사소송은 비용과 시간이 지나치게 많이 소요되므로 근로자의 신속한 권리구제를 할 수 없다는 단점이 있다. 더구나 법원이 해당 노동관행의 효력을 인정할 수 있을가에 관하여는 근로자 또는 일반인이 판단하기에 무리가 있다. 이러한 불확실한 결과의 예측을 가지고 근로자가 무리하게 민사소송을 제기한다는 것은 상상하기 어려운 일이다. 노동관행의 위반으로부터 근로자가 민사소송을 통하여 권리구제를 받기 위해서는 민사소송을 통하여 얻는 이익이 소송비용과 소요시간을 모두 상쇄하고도 남을 만큼 소익이 커야 할 것이고, 그렇지 못한 경우에는 권리구제가 어렵다고 볼 것이다. 근로계약과 관련한 분쟁에 있어서는 노동관계법에서 여러 가지 특별한 분쟁해결제도를 두고 있고 개별 사건의 심리과정에서 노동관행의 효력이 문제되는 경우 노동위원회 등을 통하여 그 효력여부에 대한 판정이 이루어질 수 있지만 노동위원회 등에 의한 판정은 신속한 권리구제에 있는 만큼 엄격한 법리해석이 이루어질 수 없고 사법적 최종판단이 아니라는 점에서 노동관행과 관련한 분쟁해결수단으로서 한계가 있음을 지적하지 않을 수 없다.

26) 박수근, 앞의 논문, 132면.

27) 박홍규, 앞의 책, 201면.

28) 프랑스는 노동관행의 요건에서 우리보다 더 엄격하다는 것을 인식할 필요성이 있다. 즉 우리와는 달리 노동관행이 되기 위해서는 일률적, 계속적, 정기적 외에 그러한 것에 대한 신뢰성이라는 주관적 요소가 필요하다고 한다[이달휴, “노동관행의 성립과 효력”, 재산법연구 제24권 제1호, 한국재산법학회(2007), 446면].

(2) 묵시적 동의

노동관행 성립의 두 번째 요건으로, 노사 당사자 모두 그 관행을 인정하거나 적어도 묵시적 동의가 있는 것으로 추정될 것이 요구된다. 관행은 이미 노사 당사자가 자기들의 노사관계를 형성하고 근로관계를 규율하고 있다는 의사를 분명하게 가지고 있음이 전제되어 있고, 만약 노사 당사자가 그 관행에 의하지 않겠다는 의사가 표출 되었다면 그러한 관행은 파기되거나 성립되지 않았을 것이기 때문이다. 노동관행은 근로자와 사용자가 그 관행에 의한다거나 의하지 않는다는 의사가 명백하지 않은 경우에 적용된다는 견해²⁹⁾도 있으나 이 경우 사실적 계약관계론에 근거하여 묵시적 동의가 추정될 수 있을 것이라고 본다. 노동관행을 이루는 개개의 행위에 대하여 노사간의 묵시적 합의가 존재한다고 추정될 수 있기 위해서는 먼저 경험칙상 그와 같이 해석이 타당하다고 인정될 수 있어야 한다. 예컨대, 개개의 행위나 처우가 일시의 혼란을 피하기 위하여 부득이하게 실시되었다는 사정이 있는 경우에는 위와 같은 추정이 성립되기 어려울 것이다. 또한, 묵시적 합의라는 성질상 당해 노동관행과 상치하는 명시적 의사표시가 존재할 경우에는 당해 노동관행에 관한 묵시적 합의가 인정되기 곤란할 것이다. 나아가, 묵시적 합의도 합의인 이상 당해 노동관행을 구성하는 개개의 행위나 처우가 사회질서나 강행법규에 반할 경우에는 그러한 행위나 처우에 관한 묵시적 합의는 무효라고 할 것이다.³⁰⁾ 우리나라 대법원은 노동관행의 성립요건으로서 당사자 간의 묵시적 규범의식의 존재가 인정되어야 한다는 입장을 취하고 있다.³¹⁾ 노동관행이 성립하는데 있어서 당사자의 의사와 관계없이 성립하는가가 문제로 된다. 의무없는 행위가 당사자의 누구도 반대 없이 장시간에 걸쳐서 과거에 반복되어 온 경우 노동관행이 성립한다고 할 수 있다고 본다.³²⁾ 착오에 의한 경영관행이 이루어지는 경우 사용자가 그와 같은 의무의 부존재를 모르고 있는 한(선의인 한) 구속력 있는 경영관행이 성립할 수 없다는 견해가 있다.³³⁾ 당사자의 의사없는 착오에 의한 노동관행은 인정할 수 없다고 보되 다만 사용자의 그러한 행위를 신뢰한 근로자의 이익의 보호를 위해 신뢰책임의 성립을 인정하여야 할 것이라고 본다.

29) 강성태, “평균임금의 범위와 산정방법”, 1997노동관계비평, 민주사회를 위한 변호사모임(1988), 98면.

30) 현경대, 앞의 논문, 486면.

31) 대판 2002. 4. 23. 2000다50701.

32) 山口浩一郎, “労働慣行と破棄”, 季刊労働法 133號, 總合労働研究所(1984), 63頁.

33) 이달휴, 앞의 논문, 453면.

(3) 보편성

관행은 집단적이고 보편적으로 이루어져야 하고 어느 특정 근로자 또는 특정 근로자집단에 대한 개별적 취급은 근로계약의 해석 기준은 될 수 있으나 노동관행이라고 보기는 어렵다는 견해가 있다.³⁴⁾ 일반적으로 보편성이란 집단 전체에 공통되거나 두루 미치는 것을 의미한다. 근로자 집단에 관계되는 관행은 집단 전체에 적용되는 관행이므로 당연히 보편성을 가지게 된다. 따라서 보편성은 근로자 집단에 관계되는 노동관행의 특징이라고 할 수 있다. 이처럼 관행의 성립요건으로 보편성을 들고 있기도 한데, 보편성은 반드시 관행성립의 필수요건은 아니라고 본다. 왜냐하면 관행은 사용자와 개별 근로자의 관계에서도 성립될 수도 있다고 보기 때문이다. 근로자 집단이 아닌, 개별 근로자에 관계되는 관행은 개별 근로자와 사용자 간에 형성되는 관행이므로 이 경우 보편성을 가진다고 할 수 없다. 따라서 관행이라고 함은 개별 근로자에 관계되는 관행 및 근로자 집단에 관계되는 관행 모두를 포함하는 개념으로 이해하는 한 보편성을 노동관행의 필요적 성립요건으로 보기는 어렵다고 할 것이다.

2. 노동관행의 변경

노동관행의 변경 또는 중단은 원칙적으로 변경계약을 통해서 이루어져야 한다.³⁵⁾ 변경계약이 아닌 새로운 노동관행이 기존의 노동관행을 대체함으로써 변경되기도 할 것이다. 관행이 근로계약의 내용보다 불리한 경우 묵시적 동의에 의한 근로계약의 변경이 이루어졌다고 볼 것인지 또는 위법 상태가 지속되고 있다고 볼 것인지에 대한 검토가 요구된다. 묵시적 동의에 의한 근로계약의 불이익 변경이 이루어졌다고 본다는 것은 사용종속관계를 특징으로 하는 노동관계에 있어서는 인정되기 어려운 면이 있다. 사용종속관계하의 근로자는 근로계약의 불이익 변경이 행해지더라도 고용관계를 유지하는 동안에는 거부하기 어렵고 설사 근로자가 동의를 했다고 하더라도 그것이 반드시 진의라고 보기는 어려운 노동관계의 특성이 있다. 기존의 노동관행을 변경하거나 폐기하기 위해서는 기존의 관행과 다른 새로운 노동관행이 성립되거나 개별적으로 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등을 변경함으로써 가능할 것이다. 근로자 집단에 관계되는 노동관행은 취업규칙에 준하는 법적 성질을 가지므로 근로자 집단에 관계되는 노동관행의 불이익한 변경은 취업

34) 박홍규, 앞의 책, 201면.

35) 김형배, 앞의 노동법, 105면.

규칙의 불이익변경에 해당하므로 반드시 법정절차를 거쳐 변경하여야 효력이 있다.³⁶⁾ 개별 근로자에 관계되는 노동관행은 근로계약에 준하는 법적 성질을 가지므로 근로계약의 불이익 변경을 위해서는 근로자의 동의를 거쳐 변경하여야 효력이 인정된다. 이미 성립된 노동관행에 의하여 취득된 근로자의 권리를 사용자가 일방적으로 불이익하게 변경하거나 폐기하는 것은 근로계약 또는 취업규칙을 위반하는 것으로서 그 정당성이 부인되거나 권리남용이나 신의칙에 반하는 것이 되어 무효가 될 수 있다.

판례는 노사당사자의 합의에 의한 노동관행의 변경을 인정하면서도 노동관행의 불이익 변경에 대해서는 근로자 과반수로 조직된 노동조합의 동의를 얻는 등의 집단적 절차를 거쳐야 한다고 한다.³⁷⁾ 노동관행의 불이익변경에 대해 노동부 행정해석에서도 “회사의 급여규정(취업규칙)에서 상여금에 대해서는 ‘별도의 지침에 따른다.’고 규정하였으나, 별도의 지침을 규정함이 없이 그 동안 상여금 지급율을 500%씩 관행적으로 지급하였다면 동 관행은 근로조건화 되었다고 볼 수 있고 관행으로 근로조건화된 상여금 지급률 등 근로조건을 변경하고자 하는 경우에는 취업규칙의 변경절차를 거쳐야 함.”이라고 하였으며³⁸⁾ 또 “중사근로자에 대하여 그간 장교경력(을 100%군복무 경력으로 인정하여 임금을 지급해 왔다면 동 관행은 근로조건화 되었다고 볼 수 있으므로 이를 근로자에게 불이익하게 변경(호봉의 재산정)할 경우에는 근기법 제97조에 의하여 당해 사업 또는 사업장에 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합, 과반수 노조가 없는 경우에는 근로자 과반수의 동의를 얻어야 함”이라고 하였다.³⁹⁾

위법상태가 지속되고 있다고 보는 경우 채무불이행 또는 불법행위에 기인한 손해배상 청구권이 인정될 수 있다. 근로계약과 다른 관행이 아무리 장기간 지속된다고 하더라도 근로계약이 바뀌기 전에는 위법행위의 관행이 적법으로 치유될 수는 없을까? 기존의 근로조건보다 유리한 관행의 경우 유리조건 우선의 원칙이 적용되고, 기존의 근로조건보다 불리한 관행의 경우에는 그 같은 관행이 아무리 장기간 지속되고 반복된다고 하더라도 기존의 근로조건에 우선하는 효력이 인정되지 않는다고 본다. 따라서 노동관행이 근로계약의 내용으로 된 경우에 그에 대한 구속력은 오로지 계약 당사자 쌍방의 합의에 의하여 배제시킬 수 있다고 보며, 부득이한 경우 근로계약전체를 해지시킬 수 있다.⁴⁰⁾

36) 김지형, 근로기준법 해설(개정 5판), 청림출판, 2001, 38면.

37) 대판 2002. 4. 23. 2000다50701; 대판 1995. 2. 14. 94다21818.

38) 2000. 6. 20. 근기 68207-1873.

39) 2002. 2. 24. 근기 68207-217.

40) 이학춘 역, 독일노동법, 한국경영자총협회, 2002, 68면 참조.

3. 노동관행의 효력

(1) 노동관행의 법원성

가. 관습법

사회의 거듭된 관행으로 생성한 사회생활규범이 사회의 법적 확신과 인식에 의하여 법적 규범으로 승인·강행되기에 이르는 것을 관습법이라고 하고⁴¹⁾ 노동관행에 있어서 관습법의 형식으로 존재하는 종속노동관계에 관한 법규범을 노동관습법이라고 한다.⁴²⁾ 어떠한 노동관행 또는 노동관습이 노동관습법으로 되기 위해서는 사회의 법적 확신에 의하여 법규범으로 지켜질 정도에 이르러야 한다.⁴³⁾ 그런데, 노동관행이 관습법으로 인정되기 위하여 필요한 ‘법적 확신’에는 당사자인 노사공동의 규범의식이 강하게 반영되어 있어야 하는데 일반적인 노동관행에 이러한 법적 확신이 존재한다고 보기는 어려울 것이라는 견해가 있다.⁴⁴⁾ 나아가 우리나라는 노사관계의 역사가 일천하고 노동법제 또한 고유한 노사관계의 현실로부터 생성·발전되어 온 것이 아니기 때문에 전국적 차원의 노동관습법이나 노동관행은 아직 존재하지 않는 단계라는 견해도 있다.⁴⁵⁾ 관습법이 되기 위해서는 법적 확신이 필요하지만 이를 확인하는 것은 쉽지 않을 뿐만 아니라, 관습법은 자연발생적인 규범이어서 그 성립시기를 확정하기 어려운 측면이 있다.⁴⁶⁾ 관행 또는 관습이 관습법으로 인정되기 위해서는 법적 확신과 이에 대한 법원의 원용이 필요하다.⁴⁷⁾

41) 대판 1983. 6. 14, 80다3231.

42) 이상윤, 노동법, 법문사, 2002, 41면.

43) 김증한, 민법총칙, 1980, 48면; 곽윤직, 민법총칙, 1989, 27면. 헌법재판소는 “관습헌법이 성립하기 위하여서는 관습법의 성립에서 요구되는 일반적 성립 요건이 충족되어야 한다. 첫째, 기본적인 헌법사항에 관하여 어떠한 관행 내지 관례가 존재하고, 둘째, 그 관행은 국민이 그 존재를 인식하고 사라지지 않을 관행이라고 인정할 만큼 충분한 기간 동안 반복 내지 계속되어야 하며(반복·계속성), 셋째, 관행은 지속성을 가져야 하는 것으로서 그 중간에 반대되는 관행이 이루어져서는 아니 되고(항상성), 넷째, 관행은 여러 가지 해석이 가능할 정도로 모호한 것이 아닌 명확한 내용을 가진 것이어야 한다(명료성). 또한 다섯째, 이러한 관행이 헌법관습으로서 국민들의 승인 내지 확신 또는 폭넓은 컨센서스를 얻어 국민이 강제력을 가진다고 믿고 있어야 한다(국민적 합의)”고 하였다[헌재 2004. 10. 21, 2004헌마554(전원재판부)].

44) 현경대, 앞의 논문, 485면.

45) 김형배, 앞의 노동법, 103면 참조.

46) 박수근, 앞의 논문, 132면.

47) 관습에 대한 관습법으로의 승격은 법원의 판결을 통한 원용이 있어야만 가능하나 관습법이 반드시 법원의 판결 이후에만 존재하는 것은 아니고 이미 존재하고 있는 관습법에 대한 법원의 확인행위이라고 보는 것이 타당하다고 본다.

나. 사실인 관습

민법 제106조는 “법령 중의 선량한 풍속 기타 사회질서에 관계없는 규정과 다른 관습이 있는 경우에 당사자의 의사가 명확하지 아니한 때에는 그 관습에 의한다.”고 규정함으로써 ‘사실인 관습’이 법률행위 해석의 표준이 됨을 규정하고 있다. 여기에서 ‘법령 중의 선량한 풍속 기타 사회질서에 관계없는 규정’이란 강행법규에 대응하는 개념으로서 임의법규를 말한다. 이와 같이 임의법규와 다른 관습이 있을 때에는 관습이 우선하여 법률행위 해석의 표준이 된다는 것이다. 노동관행의 성질을 관습법으로 보기는 어려워 민법상의 사실인 관습에 해당한다고 하는 견해가 있다.⁴⁸⁾ 또 다른 견해는 사실인 관습으로서의 노동관행이 있지만 사실인 관습이 아닌 노동관행도 있다고 하고 보통은 사실인 관습이 아닌 노동관행이나 노동관행이 보편성을 얻으면 사실인 관습으로서의 노동관행이 되고 사실인 관습으로 평가되지 않는 노동관행에 대해서는 보충규범의 효력을 인정하지 않는 것이 민법과 조화되는 해석이라고 한다.⁴⁹⁾ 노동관행이 사실인 관습이 되려면 보편성 또는 규범의식을 얻어야 하기 때문에⁵⁰⁾ 보편성 또는 규범의식을 얻은 노동관행은 사실인 관습이라고 할 수 있으나 그렇지 않은 노동관행은 사실인 관습이라고 할 수 없다. 대법원은 구속력있는 노동관행이 되기 위해서는 적어도 사실인 관습으로서의 노동관행이 되어야 하고 추가로 당사자의 묵시적 동의를 필요로 한다고 판시하고 있다.⁵¹⁾ 사실인 관습이 아닌 노동관행에 대해서는 구속력있는 노동관행으로서의 법적 효력을 인정할 수는 없다고 본다. 그러나 반복계속에 대한 신뢰는 보호할 만한 가치가 있다고 생각하므로 신의칙이나 권리남용의 법리를 적용하는데 판단요소로 작용할 수 있을 것이다.⁵²⁾ 이에 비하여 노동관행이 민법 제106조의 사실인 관습으로 인정되는 경우에는 민법의 효력을 적용할 수 있다고 생각한다. 즉 보충적 규범의 효력 내지 의사해석기준의 효력을 인정할 수 있다.⁵³⁾

48) 권혁, “노동관행에 따른 급부청구권의 형성과 소멸”, 노동법학 23호, 한국노동법학회(2006). 12, 286면.

49) 이달휴, 앞의 논문, 451-456면.

50) 山口浩一郎, 前掲書, 67頁.

51) 대판 1993. 1. 26, 92다11695; 대판 1996. 5. 10., 95다42270.

52) 이 설에 의하면 대부분의 노동관행은 사실인 관습으로 되는 경우가 대단히 적기 때문에 노동관행은 장래에는 구속력을 가지지 않는 것이 대부분 일 것이다(이달휴, 앞의 논문, 457면). 김형배 교수는 노동관행은 청구권부여적 효력을 가지며, 그 근거는 일정한 사실적 급부가 반복되는 경우에 근로자들은 앞으로도 그와 동일한 급부를 받게 될 것이라는 신뢰를 하게 되고, 이러한 신뢰는 보호되어야 하며, 이러한 근로자의 신뢰보호가 청구권의 근거로서 작용한다는 것이다. 즉 사용자는 그의 행위에 의하여 발생한 근로자의 기대에 대한 신뢰책임을 부담한다고 한다(김형배, 앞의 노동법, 104면).

53) 山口浩一郎, 前掲書, 67頁.

다. 검토

민법 제106조의 사실인 관습은 민법 제106조에 의하여 법률행위 해석의 기준이 되는 관습을 ‘사실인 관습’이라고 하여 민법 제1조에 의한 관습법과 구별하는 견해가 있고, 사실인 관습과 관습법 사이에 차이가 없다고 보는 구별부인설이 있다. 구별하는 견해가 다수설이다. 구별부인설은, 유동적인 성격이 큰 노동법의 경우 사회 전반적인 확신에 이르지 않을 지라도 하나의 부분사회, 특히 어느 노동현장에서 어느 정도 그 구성원에게 구속력을 지니는 경우에는 그 법원성을 부정할 필요는 없으므로, 노동법의 경우에는 구태여 사실인 관습과 관습법을 구별할 필요는 없다고 한다.⁵⁴⁾ 이와 달리 구별설은 사실인 관습은 ‘법적 확신’이 결여되어 있는 사실에 불과하고 법이 아니나 관습법은 사회 일반에 의해 법적 확신이나 인식에 의하여 법적 규범으로 승인될 정도에 이른 관행으로서 법이다. 관습법은 법원으로서 법령과 같은 효력을 갖는 것으로서⁵⁵⁾ 민사상의 모든 법률사실에 적용되고 법률해석의 문제가 발생하나 사실인 관습은 법률행위에 있어서 당사자의 의사가 불분명할 때 한하여 법률행위 해석의 기준이 될 뿐이다. 판례는 관습법을 법으로서 보충적 효력을 인정하는데 반하여, 사실인 관습은 일반적으로 사적사치가 인정되는 분야에서 관습의 법률행위의 해석기준이나 의사보충적 효력을 인정한 것이라고 판시하고 있어 사실인 관습과 관습법을 구별하는 입장을 취하고 있다.⁵⁶⁾ 관습법과 사실인 관습 사이에 차이점을 들어보면 첫째, 성립요건상 관습법에는 관행의 존재와 더불어 일반적으로 인정된 법적 확신이라는 요건이 필요하나 사실인 관습에는 이를 요하지 않는다는 차이가 있다. 둘째, 법원성의 유무에서 관습법은 당연히 법원성이 인정되나 사실인 관습은 존재하는 사실에 불과하고⁵⁷⁾ 관습법은 모든 민사법 영역에 있어서 법률행위에 적용되나 사실인 관습은 법률행위의 해석기준으로 적용함에 불과하다는 차이가 있다. 셋째, 주장·입증책임과 관련하여 관습법은 법원의 직권조사사항임에 반하여 사실인 관습은 당사자의 주장·입증을 요한다.

다양하고 유동적인 근로관계의 발생과 변경된 내용을 규율하는 규범이 존재하지 않거나 규범이 존재하지 않는다고 하여도 그 내용적 틈이 발생하는 경우에 이를 보완하기 위해 특정기업 또는 사업장에는 노동관행이 발생할 수 있다. 그렇게 발생한 노동관행은 일정기간 동안 반복됨으로써 사용자가 근로자들에게 지켜야 할 것으로 인식되고 기대되어,

54) 이병태, 최신노동법, 중앙경제사, 2002, 50면.

55) 대판 1983. 6. 14, 80다3231.

56) 대판 1983. 6. 14, 80다3231.

57) 사실인 관습과 관습법의 구별부인설에 따르면 사실인 관습에 대해서도 법원성을 인정한다.

규범으로서 인식의 정도 차이는 있겠지만 당사자들에게 규범으로 자리를 잡게 될 가능성이 높다.⁵⁸⁾ 이러한 노동관행을 사실인 관습으로 이해할 것인지 아니면 관습법으로 이해할 것인지에 관해서는 견해가 대립하고 있다.⁵⁹⁾ 우리학계에서는 노동관행에 대하여 사실인 관습으로 파악하려는 견해가 우세한 듯하다. 앞에서 살펴보았듯이 사실인 관습과 관습법 간의 차이는 크다고 할 수 있으므로 사실인 관습과 관습법으로 구별할 필요는 없다고 하는 견해는 찬성하기 어렵다.⁶⁰⁾

사실인 관습과 관습법 간의 법적용순위에 있어서 민법 제1조에 의하면 ① 강행규정, ② 임의규정, ④ 관습법으로 순으로 되고 제106조에 의하면 ① 강행규정, ② 사실인 관습, ③ 임의규정, ④ 관습법으로 되어 모순이 발생한다. 이 모순을 어떻게 해결할 것인가? 생각건대, 민법 제1조는 법적용순위를 정한 것인 반면 제6조는 법률행위의 해석기준을 정한 것이라고 해석한다. 즉 제1조의 해석은 법규범 간의 내용이 상충될 때 어떠한 법규범을 우선으로 할 것인지에 대하여 정한 것으로 보아야 하고, 제6조의 해석은 임의규정과 사실인 관습이 있고 임의규정에서 당사자의 의사가 명확히 드러나지 않을 때 그 법률행위의 해석기준을 사실인 관습에 의한다는 것으로 보아야 한다. 이와 달리 임의규정에서 당사자의 의사가 명확히 드러나는 경우에는 이와 다른 사실인 관습이 있어도 임의규정에 우선할 수 없다고 보아야 한다.⁶¹⁾ 노동관행의 성립요건으로서 계속성·반복성의 정도나 묵시적 합의의 추단 정도에 따라 노동관행의 법적 성질은 달라질 수 있다고 본다. 즉 노동관행은 관습법적 지위 또는 규범적 지위, 계약적 지위, 사실인 관습적 지위에 있을 수도 있고, 사실인 관습에 이르지 못한 지위에 있을 수 있다. 노동관행의 법적 지위에 따라 법적 구속력은 차이가 있으므로 노동관행의 법적 성질의 구별의 의의는 크다고 할 것이다.⁶²⁾ 어떠한 법적 지위를 갖는 노동관행에 대하여 구속력을 인정할 것인가는 법정책적으로 결정될 문제이므로 각 나라마다 다를 수 있다. 우리나라 대법원은 사실인 관습과 묵시적 합의를 갖춘 노동관행에 대하여 법적 구속력을 인정하고 있다.

(2) 구속력의 근거

노동관행이 구속력을 갖는지에 관한 논란은 노동관행을 법원으로 인정할 것인가에 있

58) 박수근, 앞의 논문, 129면.

59) 전형배, “단체협약에 예정된 근무기간을 초과한 기간에 대한 퇴직금 누진율의 판단”, 2001노동관례비평, 민주사회를 위한 변호사모임(2002), 79면.

60) 전형배, 앞의 논문, 81면.

61) 이호정, “사실인 관습, 관습법 및 임의규정의 관계”, 고시계 1987년 8월호/통권 제366호(1987. 7), 107면 참조.

62) 이영희, 노동법, 법문사, 2001, 17면 참조.

다. 노동관행을 계약으로 보는 계약설이나 규범으로 보는 규범설에 의할 때 노동관행을 법원으로 인정하는데 어려움이 없다. 규범설의 입장에서는 그 관행은 일종의 관습법으로 보기 때문에 법령과 같은 효력을 가진다고 볼 것이고, 계약설의 입장에서는 일반적으로 당해 관행은 근로계약관계의 내용이 되어 근로계약으로서의 효력을 가진다고 본다. 그러나 노동관행의 구속력의 근거를 당사자간의 묵시적 합의가 있다고 보는 묵시적 합의설의 경우 노동관행을 법원으로 인정하는데 무리가 없으나 노동관행을 계약이 아닌 사실인 관습으로 보는 사실인 관습설 또는 신뢰에 대한 책임이라고 보는 신뢰책임설에 의하는 경우 노동관행을 법원으로 인정될 수 있을 것인가에 대해서는 논란이 있을 수 있다. 사실인 관습은 법률행위의 해석과 보충을 위한 하나의 수단 내지 착안점이 될 뿐이며, 관습법과 같이 보편적 구속력을 지닌 법규범이 아니라고 보기 때문이다. 대법원은 “관습법이란 사회의 거듭된 관행으로 생성한 사회생활규범이 사회의 법적 확신과 인식에 의하여 법적 규범으로서 승인·강행되기에 이르는 것을 말하고, 사실인 관습은 사회의 관행에 의하여 발생한 사회생활규범인 점에서 관습법과 같으나 사회의 법적 확신이나 인식에 의하여 법적 규범으로서 승인된 정도에 이르지 않은 것을 말하는 바, 관습법은 바로 법원으로서 법령과 같은 효력을 갖는 관습으로서 법령에 저촉되지 않는 한 법칙으로서의 효력이 있는 것이며, 이에 반하여 사실인 관습은 법령으로서의 효력이 없는 단순한 관행으로서 법률행위의 당사자의 의사를 보충함에 그치는 것이다.”라고 하고 있다.⁶³⁾

전통적인 학설에 의하면 노동관행은 계약상의 합의가 있는 것으로 전제하거나 의제하여 법률행위책임으로서 노동관행의 효력을 인정하려는 계약설의 입장을 취하고 있다.⁶⁴⁾ 현행법이 노동관행의 구속력에 대하여 명시적 근거를 두고 있지 않은 이상, 노동관행의 구속력의 근거를 당사자의 의사를 확인하는 것에서 찾는 것이 자연스러울 수 있다. 판례는 “관행이 근로계약의 내용을 이루고 있다고 인정하기 위하여는 그와 같은 관행이 기업 사회에서 일반적으로 근로관계를 규율하는 규범적인 사실로서 명확히 승인되거나, 기업의 구성원이 일반적으로 아무런 이의도 제기하지 아니한 채 당연한 것으로 받아들여 기업 내에서 사실상의 제도로서 확립되어 있지 않으면 안된다.”고 하여⁶⁵⁾ 관행이 법적 효력을 갖기 위해서는 관행이 노사 간의 규범으로 인정될 수 있을 정도이거나 또는 묵시적 합의와 사실인 관습이 있을 것을 요구한다.⁶⁶⁾

63) 대판 1983. 6. 14. 80다3231.

64) 김형배, 앞의 노동법, 104면.

65) 대판 1993. 1. 26. 92다11695; 대판 1996. 12. 23. 95다29970.

66) 대법원은 “대우그룹 내 계열회사간의 전적이 20여 년간 계속 시행되어 왔고 현존 관리직사원의 30% 이상이 위와 같이 전직된 경력을 가지고 있다고 하더라도, 사용자가 당해 사원의 동의를 얻지 아니하고 일방적으로 다른 계열회사로 전직시키는 관행이 규범적인 사실로서 명확히 승인되었거나 사실상의 제도로서 확립되어

노동관행이 사실인 관습으로 인정될 경우 당사자 간에 구속력이 인정된다고 보는 견해가 일반적이지만⁶⁷⁾ 대법원의 판결문을 엄격히 해석하면 노동관행에 당사자를 구속하는 효력을 인정되기 위한 요건으로 사실인 관습 외에 묵시적 합의를 함께 요구하는 것으로 보인다. 결국 노동관행이 관습법에 해당하는 경우 당연히 법적 구속력을 갖는 것이며, 관습법의 정도에 이르지 못하더라도 근로계약의 당사자가 그것에 따른다는 의사가 있거나 묵시의 의사표시에 의해 합의가 성립되었다고 볼 수 있으면 근로계약 그 자체로 인정될 수 있고, 또한 묵시의 합의 정도에 이르지 못했다고 보는 경우에도 민법 제106조의 사실인 관습으로 인정되는 경우에는 민법의 효력을 적용할 수 있다고 생각한다. 즉 보충적 규범의 효력 내지 의사해석기준의 효력을 인정할 수 있을 것이다.⁶⁸⁾ 사실인 관습으로 인정될 수 없는 관행적 사실은 당사자 사이에 새로운 권리의무관계를 발생케 하지는 않는다. 그러나 관행적 사실이 존재한다는 것은 반복되어 온 개개의 행위에 대하여 노사 간의 묵시적 합의가 있었음을 의미하므로 이러한 과거의 행위는 신뢰책임을 성립시킬 수 있는 행위로 평가될 수 있을 것이다.

(3) 효력 순위

노동관행에 의한 처우는 근로계약 또는 취업규칙, 단체협약으로서의 효력을 인정받게 되고, 노동관행에 반하는 사용자의 권리행사는 권리남용 또는 부당노동행위로 취급될 수 있다. 관행의 효력순위는 관행의 법적 성질에 따라 좌우된다고 할 수 있으므로 관행이 규범이라고 본다면 관행의 효력은 근로계약보다 우위에 있고 관행이 계약이라면 근로계약과 같은 효력을 지니며 관행이 사실인 관습에 해당한다면 관행의 효력은 근로계약보다 하위에 있다고 본다. 근로계약으로 효력을 취득한 노동관행은 근기법·단체협약 및 취업규칙에 반할 수 없으며 단체협약이나 취업규칙에 우선할 수 없다. 근로계약에 규정되지 않은 부분에 한하여 보충적으로 적용되는 노동관행은 당연히 근로계약과 동등한 효력순

있다고 단정하기 어렵다.”고 판시하였는데, 판시하였는데, 이는 관행이 있었지만 노동관행의 효력을 부정한 판례이다(대법원 1993.1.26, 선고, 92다11695, 판결). 이와 달리 대법원은 약 10년간 지급되어 온 특별생산격려금의 평균임금산정기초임금에의 포함여부와 관련된 사건에서 대법원은 경영실적의 변동이나 근로자들의 업무성적과 관계없이 IMF로 인한 경제위기가 오기 전까지 근로자들에게 정기적·계속적·일률적으로 기본급의 250%에 해당하는 특별생산격려금이 지급되어 왔다면 이는 근로계약이나 노동관행 등에 의하여 사용자에게 그 지급의무가 지워져 있는 것으로서 평균임금 산정의 기초가 되는 임금에 해당한다고 봄이 상당하다고 판시하였는데, 이는 관행에 대하여 노동관행의 효력을 인정한 판례이다((대판 2001. 10. 23, 2001다53950)

67) 권오성, 앞의 논문, 193면; 이은영, 민법총칙, 박영사, 2005, 432면.

68) 박홍규, 앞의 책, 202면 참조.

위를 가진다. 일종의 사실인 관습에 지나지 않는 노동관행은 근로계약의 상위에 있는 것으로 볼 수 없다고 본다.⁶⁹⁾ 계약설이나 규범설의 입장에 의하면 노동관행은 법원으로서의 지위를 가진다. 그러나 신뢰책임설의 입장에서는 노동관행은 일종의 사실인 관습에 불과하고, 당사자 간의 계약에 의하여 그 효력이 배제될 수 있기 때문에 노동관행의 효력 순위는 근로계약의 하위에 있는 것으로 해석하여야 한다고 보고 있다.⁷⁰⁾

노동관행이 근로계약이나 취업규칙, 단체협약에 배치되게 이루어지는 경우가 있다. 관행과 근로계약이나 취업규칙, 단체협약의 내용과 다를 경우 관행의 효력을 인정할 수 있을 것인가? 근로계약서상에 명문화된 내용과 다른 노동관행이 존재하게 되었을 때, 근로계약의 내용을 하회하는 노동관행의 규범성은 인정할 수 없되, 노동관행이 근로계약에서 정한 내용보다 상회할 때는 유리조건우선의 원칙에 따라 노동관행의 규범성을 인정하여야 할 것으로 본다.⁷¹⁾ 근로계약보다 유리한 관행에 유리조건우선의 원칙을 적용하지 않으면 관행의 법적 효력이 발생하지 않게 되는데, 관행의 법적 효력을 부여하기 위해서는 관행을 근로계약화 해야 한다. 이는 번거로울 뿐만 아니라, 이미 규범화된 노동관행이라 하더라도 근로자는 사용종속적 지위에 놓여있기 때문에 이러한 노동관행을 근로계약의 내용으로 반영시켜 줄 것을 사용자에게 요청하기 어렵다. 만약 그러한 요청이 있다고 하더라도 사용자가 이를 수용할 확률은 낮으며, 사용자는 오히려 그러한 요청시점부터 노동관행을 원래의 근로계약의 내용대로 변경할 노력을 시도할 것이기 때문이다. 따라서 노동관행이 근로계약이나 취업규칙, 단체협약에 배치되는 경우, 유리조건 우선의 원칙을 적용하여 그 노동관행이 근로계약이나 취업규칙, 단체협약에서 정한 근로조건 기타 근로자 대우에 관한 기준을 상회한다면 당해 노동관행이 우선 적용되고, 하회한다면 계약위반 또는 취업규칙 등 위반으로 그 효력이 없다고 보아야 한다.⁷²⁾

69) 김형배, 앞의 노동법, 105면 참조.

70) 위의 책, 105면.

71) 이학춘 역, 앞의 책, 67면 참조. 어떠한 수당을 통상임금에 포함시키는 것에 대하여 오랫동안 노사 간에 아무런 이의 없이 실시되어 온 경우 노동관행이 되어 청구권의 근거가 될 수 있다고 할 수 있겠지만 이러한 노사의 합의는 통상임금에 대한 법적인 정의까지 변경할 수는 없다. 따라서 이 경우 수당과 관련된 청구권의 근거는 통상임금이기 때문이 아니라 통상임금과 같이 취급하자는 노사간의 관행이 있기 때문이라고 할 수 있고 이러한 관행은 근로자에게 보다 유리한 내용이므로 유리조건 우선의 원칙이 적용되어 그 효력이 인정된다고 하겠다.

72) 박홍규, 앞의 책, 203면.

IV. 신뢰책임의 성립과 효력

1. 개념 및 성질

‘신뢰책임’이란 일정한 자가 스스로의 의사에 기한 자기 결정이 없이 만들어진 행위 기타 외관에 의하여 타방에게 일정한 법적 상태가 존재한다는 신뢰를 조성시킨 경우 그 타방에게 신뢰한 대로의 급부 또는 그 신뢰로 인한 손해를 배상할 의무를 부담하게 되는 것을 말한다.⁷³⁾ ‘신뢰’는 겉으로는 진실한 것처럼 보이나 실제로는 진실과 다른 것을 진실한 것으로 믿는 것을 말한다. 신뢰의 개념에 대해 “신뢰에서의 기대의 정도는 희망보다는 높으나 확신보다는 그 정도가 낮은 위치에 있다.”고 한다.⁷⁴⁾ 민법상 신뢰가 법률적으로 어떠한 지위를 가지는지에 대해 독일에서 두 가지 측면의 견해가 있다. 첫째는 진실한 권리관계 또는 의사표시에서의 내심적 효과의사와는 다른 외형이 있는 경우에는 외부로 나타난 사실에 의한 법률효과가 발생하여야 한다는 권리의관론(표시주의론)이며, 둘째는 책임법분야에서 신뢰이익을 독립된 민사법익으로 파악하여 불법행위책임과 계약책임의 중간영역으로서 별도의 독립된 신뢰책임을 인정하여야 한다는 견해이다.⁷⁵⁾ 신뢰법리가 적용되어 구성되는 책임이 신뢰책임이다. 신뢰책임은 자신의 의사와는 무관하게 성립한다는 공통점이 있지만 불법행위는 단순히 타인과의 생활관계에서 발생하고 신뢰책임은 당사자 사이에 특별한 결합관계를 요구한다는 차이가 있다. 계약책임과 신뢰책임은 당사자 사이에 특별한 결합관계를 가지고 있다는 공통점이 있지만 계약책임은 당사자의 의사를 필요로 하고 신뢰책임은 당사자의 의사를 요구하지 않는다는 점에서 차이가 있다. 법률행위책임의 본질은 개인의 자발적이며 자유로운 의사결정에 의한 의사책임임에 반하여 신뢰책임의 본질은 자기의사에 의한 자기결정없이 일정한 상태를 기초로 하여 성립하는 법정책임이라는 차이가 있다.⁷⁶⁾

2. 근거 및 한계

신뢰책임은 법률관계에 있어서 어떤 자에게 생긴 신뢰는 가능한 한 보호되어야 한다는

73) 정준영, 앞의 박사학위논문, 7면.

74) Hermann Eichler, *Die Rechtslehre vom Vertrauen*, 1950. S. 3.

75) 장재현, “민법상의 신뢰책임”, 법학논고 제16집, 경북대학교 법학연구소(2000), 36면.

76) Canaris, op. cit., S. 429f.

신뢰보호사상에 근거를 두고 있다. 당사자가 어떠한 법률효과의 발생을 의욕하였다는 데에 기하여 일정한 법률효과가 생기는 것이 아니고 상대방이 그러한 의욕을 가지리라고 신뢰한 데에 기하여 생긴다.⁷⁷⁾ 신뢰책임은 법률관계에 있어서 선의의 제3자를 보호하거나, 거래상대방을 보호함으로써 거래의 안전을 도모하기 위해 생겨났다. 자본주의 경제체제에서의 거래질서는 상대방 및 일정한 외양에 대한 신뢰가 전제할 때에만 가능하다. 신뢰책임을 인정하지 않게 되면 허위의 행위자를 보호하고 진실한 권리자를 희생시키는 결과를 가져온다. 신뢰책임의 실정법적 근거는 민법 제2조의 신의성실의 원칙에서 찾을 수 있다. 그 밖에도 민법상의 비진의표시, 표현대리, 계약체결시의 과실책임 등에 관한 규정은 이러한 신뢰책임의 실정법적 근거가 된다.⁷⁸⁾

외형적으로는 자유로운 의사의 결정으로 보여지나 원천적으로 자유로운 의사의 결정이라고 볼 수 없는 사회적 약자의 경우 그 의사표시대로 법률행위의 효과가 발생할 수 없다. 노동관계에 있어서 개별 근로자는 사용자에게 대하여 상대적 약자이므로 자유로운 의사의 결정에 의한 법률행위가 이루어지지 않는 경우가 많다. 이러한 경우 그 의사표시대로의 법률행위의 효과는 발생하지 않을 수 있으나 그 대신 신뢰책임이라는 법정책임이 성립할 수 있다. 예를 들어 사용자가 근로자에게 일정한 금전을 지급하면서 이는 임금인 아닌 경영성과의 변동 및 업무성적에 따라 지급하는 성과급이라고 의사표시를 하였지만 경영성과나 업무성과와 관련없이 장기간 반복적으로 지급해 오다가 중단한 경우 그러한 관행이 구속력 있는 노동관행으로 인정될 때에는 근로자는 금전지급청구권을 가지게 되나 노사간 의사의 합치 또는 묵시적 승인이 부정되는 경우 구속력 있는 노동관행으로 인정될 수 없어 근로자는 금전지급청구권을 가질 수 없게 된다. 근로자에게는 경영성과나 업무성과와 관련 없이 장기간 반복적으로 지급해 온 사실에 대한 신뢰가 형성되고 그러한 신뢰가 노사관계에 반영하여 왔다고 할 수 있다. 근로자는 근로의 대가로서 임금외 그만큼의 성과급을 받는 것으로 확신하게 되고 노사간 임금협상에서 근로자와 사용자는 의식적이든 무의식적이든 그 성과급 부분을 감안하여 임금협상을 진행했을 가능성이 높다. 향후 사용자의 자의로 성과급지급을 중단할 가능성에 대비해서 근로자가 성과급에 대한 지급청구권을 명확히 하기 위해 단체협약이나 취업규칙, 근로계약 등으로 명문화화를 시도하면 사용자는 즉시 그 동안의 성과급지급관행을 더 이상 반복하지 않을 것이다. 장기간 반복된 관행을 신뢰하여 당연히 이후에도 그러한 관행이 유지될 것으로 기대하고 그러한 기대가 거래관계에 자연스럽게 반영되어 왔지만 그러한 관행이 구속력 있는 노동관행으로 인정되지도 않고 규범이나 계약으로 전환할 수도 없고 오직 한쪽 거래당사자의 일방

77) 김학동, “신뢰책임과 법률행위이론”, 민사법학 제7호, 한국민사법학회(1988), 23면.

78) 장재현, 앞의 논문, 37면.

에 의해 그 거래관계가 좌우된다면 이는 거래의 안전을 해치는 결과가 된다. 이처럼 자기 의사에 의한 결정이 없음에도 불구하고 법외관을 신뢰한 경우에 이행의무를 저야 할 필요성 내지는 이행의무를 정당화시키는 신뢰책임의 근거는 거래보호의 필요성에서 찾을 수 있다.

자유로운 의사결정이 보장되는 사적자치의 분야에는 신뢰책임을 물을 필요없이 그 의사표시대로 법률행위의 효과가 발생하도록 하면 된다. 그러나 신뢰책임은 본인의 의사결정과는 무관하게 일정한 외양을 기초로 성립하는 법정책임이기 때문에 신뢰책임은 자유로운 의사표시를 기초로 하는 전통적인 법률행위론의 예외에 속하는 분야에서 성립할 수 있다. 신뢰책임의 법리는 강행법규나 공서양속 또는 사회질서의 위반의 행위에는 적용되지 않고 사적자치의 영역에 한정하여 적용되는 것이나 사적자치의 분야 중에서 절대적으로 개인의 자유로운 의사를 필요로 하는 법률행위에는 적용되지 않을 것이다. 예를 들어 가족법관계에서와 같이 개인의 의사를 절대적으로 필요로 하는 영역에서는 신뢰책임이 적용되는 경우는 많지 않을 것이다.

신뢰책임이 성립하기 위한 요건으로 일정한 외관이 있어야 하는데, 외관이 있다고 무조건 외관을 현출한 신뢰야기자가 신뢰책임을 저야 하는가? 신뢰의 외관형성에 신뢰야기자 본인의 고의·과실이 있는 경우에는 문제가 되지 않는다. 그러나 신뢰야기자 본인에게 고의·과실이 없는데도 거래상대방을 보호하기 위하여 신뢰책임을 무조건 인정한다면 형평성에 맞지 않게 된다. 어떠한 경우에 신뢰야기자에게 신뢰책임을 인정할 것인가가 문제된다. 이러한 신뢰책임의 귀책성의 근거에 관한 학설로 원인제공론과 위험의원칙론이 있다. 원인제공론은 거래상대방을 폭넓게 보호함으로 인해 지나치게 신뢰야기자 본인이 희생될 뿐더러 민법상 과실책임주의원칙에 부합하지 않는다는 비판이 있는 반면 위험의원칙론은 본인과 거래상대방의 형평을 고려한 점에서는 바람직하나 거래상대방은 자신의 귀책사유없이 자신의 권리를 상실할 수 있다는 문제점이 있다. 여기서 거래상대방의 귀책사유는 선의·무과실을 의미한다. 생각건대 신뢰야기자나 거래상대방 모두 귀책성이 없는 경우 누구의 위험부담으로 할 것인가 입법정책적으로 결정할 문제이나 신뢰책임이 거래상대방의 보호 또는 사회적 약자 등의 자유로운 의사결정을 전제로 하지 않는 법률관계에서 성립한다는 점을 고려해보면 신뢰야기자보다는 신뢰자의 보호에 무게를 둔 원칙을 정하되 신뢰책임의 성립 및 책임의 크기는 구체적 사건에 있어서 제반 상황을 종합적으로 고려하여 판단할 수 있을 것으로 본다.

3. 성립 요건

신뢰책임이 성립하기 위해서는 당사자 사이에 특별결합관계가 존재하여야 하며 신뢰의 대상인 법률행위적 표지가 존재해야 한다. 여기서 특별한 결합관계라는 것은 우연한 접촉 이상의 특별한 관계를 의미하는데, 이는 적어도 일방당사자가 일정한 행위에 의해 타방당사자에게 신뢰를 야기하는 결합의 특성을 통해 특징지워진다. 그리고 신뢰책임을 부담하는 자에 대한 요건으로서 그에게 법률행위적 표지의 형성에 대한 귀책성이 있어야 하며, 신뢰자에 대한 요건으로는 신뢰자가 법률행위적 표지에 대해 신뢰하고, 신뢰를 함에 있어 선의여야 하며 그러한 신뢰에 기하여 일정한 조치를 해야 하고, 신뢰와 조치간에 인과관계가 있어야 한다.⁷⁹⁾ 당사자는 신의성실에 따라 상대방의 행위를 신뢰하며 이 때 상대방의 직업상의 위치, 상대방의 표시, 태도 등이 신뢰를 유발하는 원인이 될 수 있고 당사자들은 신뢰상황에 관해 알고 있어야 하고 신뢰관계는 의식적으로 이루어져야 한다고 한다.⁸⁰⁾

신뢰책임이 성립하기 위해서는 일단 타인의 진실한 의사표시가 행하여졌다는 외형이 존재하여야 하는데, 외형의 존재가 있을 때 본인의 고의 또는 과실을 요하는가가 문제된다. 신뢰책임은 신뢰자의 신뢰를 보호함으로써 상대적으로 신뢰야기자의 권리를 희생시키는 것이므로 신뢰야기자의 의사와 무관하게 책임을 지는 결과를 가져온다. 따라서 무조건적인 신뢰책임을 인정은 곤란하며 신뢰책임을 묻기 위해서는 단순히 본인의 행위를 신뢰한 상대방을 보호한다는 이유 외에 본인에게 책임을 부담시킬 수 있는 귀책성이 있어야 한다. 본인에게 고의 또는 과실이 있는 경우에는 신뢰책임을 성립시키는데 있어서 문제가 되지 않으나 고의 또는 과실이 없는 경우 귀책성의 근거를 어디에서 찾을 것인가에 대한 논의가 필요하다. 이에 대하여 상대방의 신뢰에 원인을 제공하였다면 책임도 수반된다는 ‘원인제공론’이 대두되었다. 원인제공론은 원인만 제공하면 무조건 책임을 진다는 것이기에 민법상 과실책임주의원칙에 부합하지 않는다는 비판으로부터 자유롭지 못하였다. 그 후 신뢰자와 원인을 제공한 자 간에 누가 책임(위험)을 부담하는 것이 더 공평한가라는 측면에서 이익교량을 통한 책임의 귀속을 결정해야 한다는 ‘위험원칙론’이 더 유력하게 받아들여지고 있다. 생각건대 신뢰책임에 있어서 귀책성은 원칙적으로는 법정책적으로 정할 문제이나 민법의 원칙에 조화되기 위해서는 과실의 유무를 전혀 고려하지 않아서는 안된다고 본다. 따라서 신뢰야기자에게 과실이 전혀 없고 신뢰자에게 과실이

79) 정준영, “신뢰책임의 체계적 구성과 민법상 적용”, 재산법연구 제25권 제2호, 한국재산법학회(2008), 42면.

80) 정준영, 앞의 박사학위논문, 67면.

있는 경우 신뢰책임이 성립하지 않으며 신뢰자에게 과실이 있는 경우라도 신뢰야기자에게 과실이 있다면 상계법리를 적용하여 책임의 정도를 규명하여야 한다고 본다.

본인의 귀책성 외에 신뢰인의 선의 또는 무과실이 필요한가에 대한 논의가 필요하다. 신뢰인은 외형의 존재에 대해서는 인지하고 있어야 하나 진실한 법률관계에 관해서는 선의여야 한다. 신뢰인의 선의에 과실이 없을 것을 요하느냐는 원칙적으로 법정책에 달려 있는 문제이나 일반적으로 신뢰인에 대해서는 선의·무과실이 추정되므로 신뢰책임을 지는 자가 신뢰인의 악의 또는 과실을 입증해야 한다.⁸¹⁾ 착오에 의해 가장된 법률관계를 진실한 법률관계로 잘못 알고 믿은 경우 또는 진실한 법률관계임을 알지 못한 경우 모두 포함된다. 이러한 신뢰인의 선의에는 과실이 없어야 한다.⁸²⁾

신뢰자는 외관을 보고 신뢰에 기하여 그에 대응하는 '일정한 조치'가 있을 것을 요한다. 일정한 조치라 함은 보통의 경우 법률행위가 되겠지만 이에 한하지 않으며 법적 보호할 가치 있는 행위이면 족하다. 신뢰자가 신뢰야기행위에 대한 신뢰에 기하여 일정한 조치를 행하였다면 유상·무상을 불문하고 신뢰책임을 인정해야 할 것이다. 신뢰자가 신뢰에 기하여 그에 대응하는 일정한 조치가 있었다면 그 일정한 조치와 신뢰 간에는 인과관계가 필요하다. 신뢰와 일정한 조치 간의 인과관계는 내부적 사실에 해당하기 때문에 그 입증이 매우 어렵다. 따라서 인과관계의 입증에 대해서는 입증책임을 전환하여 신뢰를 야기한 자에게 입증책임을 부여하는 것이 타당하다고 한다.⁸³⁾

4. 신뢰책임의 효과

신뢰책임의 법률효과로 이행책임과 손해배상책임을 들 수 있다. 이행책임의 성립요건으로는 외형의 존재와 본인의 귀책성만으로 충분하나 손해배상책임의 성립요건으로는 외형의 존재와 본인의 귀책성 외에 손해가 발생하여야 하며 그 손해는 신뢰와 인과관계가 있어야 한다. 손해에는 적극적 손해 및 소극적 손해를 포함한다. 신뢰와 발생한 손해 간 인과관계는 반드시 직접적임을 요하지 아니하며 그 입증책임은 신뢰인에게 있다. 신뢰책임의 효과는 신뢰를 하게 되는 모양에 따라 신뢰한 바를 기초로 법률효과를 그대로 인정하기도 하고 허위를 진실한 상태로 복원시키되 그로 인한 상대방의 손해를 배상케 하는 법률효과를 부여하는 것이기도 하다.⁸⁴⁾ 이행책임이든 손해배상책임이든 일반적인 신뢰

81) 앞의 박사학위논문, 74면.

82) 장재현, 앞의 논문, 41-42면.

83) 정준영, 앞의 박사학위논문, 76면.

84) 장재현, 앞의 논문, 36면.

책임의 근거는 민법 제2조의 신의성실의 원칙에서 찾을 수 있다. 물론 그 외에 관습법이나, 계약체결상의 과실책임, 표현대리 등도 그 근거가 될 수 있다.⁸⁵⁾

신뢰의 크기 정도에 따른 신뢰책임의 법적 효력을 어떻게 부여할 것인가가 문제인데, 신뢰의 크기 정도에 비례하여 신뢰책임의 법적 효력의 크기를 연동하는 방법을 생각해 볼 수 있다. 쉽게 말하면 약한 신뢰이면 그 책임도 약하게, 강한 신뢰이면 그 책임도 강하게 부여하는 것이다.⁸⁶⁾ 즉 신뢰의 크기 정도에 따라 손해배상액의 크기가 연동된다. 예를 들어 연말보너스를 매년 100%씩 4년간 연속지급한 행위를 노동관행으로 인정하는 경우에 있어서, 연말보너스를 100%씩 3년간 연속지급하다가 그 다음해 지급하지 않은 경우 노동관행으로 인정되지 않아 노동관행의 효력은 주장하지 못하게 되나 신뢰책임은 물을 수 있다고 본다. 이 경우 근로자가 신뢰책임을 이유로 보너스 지급청구를 할 때, 보너스 지급이 과거 3년간 계속되었다는 것은 아주 강한 신뢰책임이 성립하였다고 볼 수 있으므로 미지급 보너스 전액의 90% 정도의 청구권이 인정된다고 볼 수도 있다.⁸⁷⁾ 이와는 달리, 연말보너스를 100%씩 2년간 지급하다가 그 다음해 지급하지 않은 경우 근로자가 신뢰책임을 이유로 보너스 지급청구를 하였을 때, 보너스 지급이 2년간 계속된 것은 3년간 계속된 것보다 약한 신뢰책임이라고 보아야 하므로 미지급 보너스 전액의 90%보다 더 적은(예를 들어 청구액의 50% 또는 80% 등) 액수에 대한 청구권이 인정되어야 한다. 3년간 지속된 신뢰책임과 2년간 지속된 신뢰책임과의 사이에 있어서 법적 효력에 차이를 두는 것이 법이념에 부합하는 일이다.

한편, 신뢰책임의 크기 정도에 비례한 법적 효력을 부여할 수 없는 경우가 있는데 이때에는 어떻게 해야 할 것인가? 예를 들어 근로계약 갱신을 2년간 반복하여 오다가 갱신하지 않은 경우와 근로계약 갱신을 3년간 반복하여 오다가 갱신하지 않은 두 경우 모두 기대권 침해가 있다고 가정한다. 이때 2년간의 근로계약 갱신이라는 약한 신뢰책임과 3년이라는 강한 신뢰책임으로 구분될 수 있는데, 두 경우 모두 신뢰책임의 법적 효력을 인정

85) 앞의 논문, 37면.

86) 이러한 시도는 기대권 이론에서 다루어질 수 있다. 권리의 유형 중 기대권이라는 것은 현재의 권리가 침해되지는 않더라도 미래에 기대할 수 있는 권리를 침해하는 경우 권리침해에 의한 손해배상청구권을 인정하는 것이다. 이때 미래에 기대할 수 있는 권리는 강한 기대일 수도 있고 약한 기대일 수도 있다. 즉 퇴직 시 받는 퇴직금청구권이 침해된 경우 퇴직이 되면 반드시 받을 수 있는 권리이므로 이러한 권리가 침해되면 강한(완전한) 기대권을 침해한 것이고 손해배상도 온전히 해야 한다. 이와는 달리 근로자가 업무 중 사망하면 지급한다는 특별위로금을 지급하도록 규정된 경우 근로자는 '업무상 재해로 인한 사망'이라는 조건이 실현되면 그 권리를 취득한다는 점에서 조건부권리 즉, '미확정 기한부 권리'의 성질을 갖고 있다고 본다. 다만 그 조건의 실현 확률이 낮다고 할 수 있으므로 권리보호 수준이 약한 기대권의 일종이라고 본다. 이러한 약한 기대권이 침해된다면 권리침해에 대한 손해배상의 정도가 약하게 이루어져야 한다.

87) 물론 이 경우 노동관행으로 인정된 상태는 아니라고 가정한다. 미지급 보너스 전액의 100% 지급은 노동관행으로 인정받았을 때 가능하다고 본다. 노동관행으로 인정되지 못하면 노동관행에 기한 청구권은 부정되지만 신뢰책임론에 의해 신뢰의 크기에 비례한 정도의 청구권을 인정한다.

한다고 가정할 때 약한 신뢰책임과 강한 신뢰책임의 법적 효력의 차이는 어떻게 구분될 수 있을까? 신뢰책임위반으로 부당해고가 인정되면 해고는 사법상 무효가 되고 복직이 전제된다. 복직은 약한 신뢰책임이든 강한 신뢰책임이든 차이를 둘 수 없어 동일하게 적용할 수밖에 없다.⁸⁸⁾ 두 경우 신뢰의 크기에 따른 법적 효력의 차이를 둔다고 할 때 과거의 근로계약 갱신 기간(횟수)만큼 복직 후 근로계약기간을 인정하는 방법 등을 생각해 볼 수 있다. 신뢰책임의 모습에 따라 다양한 형태가 존재할 것이라고 보므로 그 효력 부여방법에 대해서 단적으로 말하기는 어렵다. 신뢰책임의 법적 효력의 적용에 있어서 개별 상황에 따라 이러한 원칙을 적용한다면 당사자들이 느끼는 권리 대비 책임의 크기 간의 괴리를 줄이고 쌍방의 만족감을 증대시킬 수 있을 것이라고 본다. 과실상계의 법리에 따라 손해배상책임의 크기를 결정하는 것과 마찬가지로 신뢰책임의 경우에도 본인의 외관작성에 있어서의 잘못의 경중, 외관이 가지는 신뢰가치의 정도 그리고 거래보호요구의 강도에 따라 외관작성자에게 지을 책임의 크기를 결정하는 것이 법의 태도에 부합하는 것이라고 할 것이다.⁸⁹⁾

V. 노동관행 및 신뢰책임과의 관계

관행과 신뢰책임과의 관계를 알아보자. 관행의 법적 성질을 신뢰책임으로 보는 경우 관행이 있으면 반드시 신뢰책임이 인정되는가? 반대로 신뢰책임이 인정되면 관행이 있는 것으로 보게 되는가? 관행의 성립요건을 보면 계속성·반복성과 묵시적 동의를 들 수 있다. 관행의 성립요소의 하나로 계속성·반복성을 요구하고 있는데, 신뢰책임의 성립요건으로는 반드시 계속성·반복성을 갖출 필요는 없는 것으로 보인다. 즉 단 한 번의 행위라도 상대방이 신뢰 또는 기대감을 가질 수 있었다면 신뢰를 준 자는 신뢰책임을 부담한다고 본다. 즉 어떠한 행위가 장기간 계속되거나 수회 반복되지 않더라도 신뢰는 형성될 수 있는 것이다. 관행의 또 다른 성립요건으로 묵시적 동의를 들 수 있는데 이는 관행의 성립은 당사자의 의사에 기초한다는 것을 의미한다. 이와 달리 신뢰책임은 신뢰책임을 부담하는 자의 자기의사 또는 자기결정이 불필요하다. 이런 점에서 신뢰책임은 법률행위책

88) 물론 해고로 인해 받지 못한 소급임금의 액수에는 차이를 둘 수 있을 것이나 해고기간이 짧다면 소급임금에 있어서도 차이를 두기 어려울 수도 있다.

89) 김학동, 앞의 논문, 30면.

임과는 구별되는 법정행위 책임이라고 할 수 있다.⁹⁰⁾ 따라서 관행과 신뢰책임의 성립요건은 같지 않으며 관행보다 신뢰책임이 먼저 성립할 수 있다. 그러나 신뢰책임보다 관행이 먼저 성립하기는 어렵다고 본다. 관행은 계속성·반복성과 묵시적 동의의 두 요건을 충족해야 하지만 신뢰책임은 이 두 가지 성립요건 한 가지 또는 두 가지 모두를 충족하지 않아도 성립 가능할 수 있다고 보기 때문이다.

신뢰책임은 사적자치가 배제되는 강행규정이 적용되는 분야나 법률행위책임이 적용되는 분야에는 적용되지 않는다. 관행의 법적 성질을 계약설, 규범설로 보는 견해에 의하면 어떠한 행위에 대한 신뢰책임이 성립하더라도 그것이 관행으로 인정될 수 있는 것이라면 관행의 법적 효력이 발생하고 신뢰책임은 적용되지 않는다고 본다.⁹¹⁾ 그렇다고 신뢰책임이 성립하지 않는다고 볼 것은 아니고 신뢰책임을 원용할 필요가 없어졌다고 볼 것이다. 법원이 관행의 성립에 엄격한 태도를 취하기 때문에 관행의 인정이 쉽지 않고 또 관행이 부인되면 당사자 일방이 모든 것을 잃는다. 이러한 관행인정과 관련하여 존재하는 불합리한 점을 보완하는 방법으로 신뢰책임을 원용할 수 있다고 본다. 어떠한 계속적·반복적 행위가 관행으로 인정받는 범위 내에 있는 경우에는 관행의 법적 효력에 의해 완전한 권리가 보장되지만 관행으로 인정받는 범위 내에 포섭되지 못하는 경우 관행의 법적 효력이 발생하지 않기 때문에 관행의 법적 효력에 근거한 권리는 보장받지 못한다. 앞에서 언급하였듯이 관행으로 인정받지 못하는 계속적·반복적 행위는 신뢰책임에 의한 청구권이 인정될 수 있다. 어떠한 계속적·반복적 행위가 관행으로 인정되지 않더라도 신뢰책임은 성립될 수 있기 때문이다.⁹²⁾ 이때 신뢰책임의 크기는 계량적 방식으로 이루어질 수 있고 그렇게 하는 것이 공정하다. 계량적 방식으로 계속성·반복성 여부를 평가하게 되면 약한 단계, 중간 단계, 강한 단계 등 적당한 단계로 구별할 수 있을 것이다.

신뢰책임의 성립에 당사자의 묵시적 동의는 불필요하다. 신뢰책임은 묵시적 동의와 관계없이 계속성과 반복성만으로 평가된다. 계속성·반복성 정도에 대한 판단이 ‘약하다’ 또는 ‘강하다’ 형태로 나타나게 되면 신뢰책임의 성립은 어떻게 될 것인가? 결국 신뢰책임의 성립은 약한 신뢰책임 또는 강한 신뢰책임의 형태로 구분될 수 있을 것이다. 관행으로 인정되지 못한 신뢰책임 중에서 강한 신뢰책임은 관행에 매우 가까운 위치에, 약한 신뢰책임은 관행에서 먼 위치에 있다.

90) Canaris, op. cit., S. 428f.

91) 정준영, 앞의 박사학위논문, 12면.

92) 법적 구속력이 있는 관행은 규범적 효력에 의해 또는 계약상 법률행위에 의한 책임이 성립한다. 민법상 법률행위책임만으로는 당사자간의 법률관계를 온전히 설명하기 곤란한 영역에 대해 신뢰책임을 인정함으로써 법률행위책임에 전적으로 의존할 경우에 초래될 수 있는 거래 안전의 불안정성을 보완하고 당사자간의 구체적 형평을 도모할 수 있다는 점에서 신뢰책임의 인정 의미는 크다(위의 박사학위논문, 41면).

노사관행을 구속력이 있는 노사관행과 구속력이 없는 노사관행으로 구별할 수도 있을 것인 바, 구속력이 없는 노사관행이라도 그러한 관행이 존재한다는 것은 반복되어 온 개개의 행위에 대해 묵시의 합의가 있었다는 것을 의미하므로 이러한 과거의 행위는 적법한 법적 근거가 있는 정당한 행위로 평가될 수 있을 것이며, 따라서 구속력이 없는 노사관행에 근거해 근로자가 받은 급부는 부당이득에 해당되지 않고, 근로자가 행한 행위는 불법행위에 해당하지 않는다.⁹³⁾ 아울러 구속력이 없는 노동관행은 노동관행으로서의 법적 효력을 주장할 수 없을 것이나 신뢰책임에 근거한 이행책임 또는 손해배상책임을 물을 수는 있을 것이다.

대법원 판례⁹⁴⁾를 하나 살펴보기로 한다. 본 사건에서 원심은 “피고의 노사간에는 창사이래 해당 연도의 임금을 인상하기로 하는 내용의 단체협약이 체결되면 단체협약 체결일 당시 재직 중인 직원들 및 그 직전 년 12. 16.부터 해당 연도 단체협약 체결일 전일까지 사이에 퇴직한 직원들에게 해당 연도에 체결된 단체협약에 따라 산정된 임금인상분 차액을 추가 지급하고 나아가 퇴직한 직원들에게는 위에서 본 바와 같은 퇴직금인상분 차액을 추가 지급하는 관행이 존재하여 왔고, 이에 대하여 노사 쌍방으로부터 아무런 이의도 제기되지 아니하였으므로, 피고의 노사간에는 위와 같은 방식에 의한 임금 추가 지급이 하나의 묵시적 규범으로 인식되어 정착되기에 이른 이른바 노동관행이 성립되었다고 볼 수 있다.”라고 하여 원심은 이 사건에서 노동관행의 성립을 인정하였다.

그러나 이러한 원심의 판단에 대해 대법원은 “노동조합이 사용자측과 기존의 임금·근로시간·퇴직금 등 근로조건을 결정하는 기준에 관하여 소급적으로 동의하거나 이를 승인하는 내용의 단체협약을 체결한 경우에 그 동의나 승인의 효력은 단체협약이 시행된 이후에 그 사업체에 종사하면서 그 협약의 적용을 받게 될 노동조합원이나 근로자들에 대해서만 생기고 단체협약 체결 이전에 이미 퇴직한 근로자에게는 위와 같은 효력이 생길 여지가 없으며” 또 “원심이 내세우는 노사관행이 피고가 이미 퇴직한 근로자들에게까지 임의로 임금인상분 및 퇴직금인상분 차액을 추가 지급하여 준 사실을 말하는 것이라면, 그것은 노동조합 또는 근로자 집단과 사용자 사이에 있었던 사실이 아니라, 이미 퇴직한 근로자들과 사용자였던 피고 공사 사이에 있었던 외부적 사정에 불과하므로, 그로써 노동조합 또는 근로자 집단과 사용자 사이의 노사관행이 성립할 수도 없는 것이다. 다만, 원고들로서는 피고에 재직할 당시 피고가 이미 퇴직한 근로자들에게 위와 같이 임금 및 퇴직금인상분 차액을 지급하여 온 사실에 기하여 자기들도 퇴직하게 되면 같은 대우를 받을 것이라는 기대를 가지고 있었다고 볼 수는 있으나, 이러한 기대가 원심이 인정하

93) 현경대, 앞의 논문, 486면.

94) 대판 2002. 4. 23, 2000다50701.

는 바와 같은 조건부채권이 되기 위해서는 피고와 그 재직 근로자들 사이에서 규범적으로 ‘단체협약이 퇴직자에게도 적용된다.’는 내용의 노사관행이 성립되어 있었어야 할 것이다.” 라고 판시한 바 있다.

생각건대, 대법원이 단체협약의 적용은 그 시행 후 그 사업체에 재직 중인 노동조합원이나 근로자들에 대해서만 생기고 단체협약 체결 이전에 이미 퇴직한 근로자에게는 위와 같은 효력이 생길 여지가 없다고 판단한 것은 ‘노동관행의 효력’이 아닌 ‘단체협약의 효력’에 관한 것으로서 옳다고 본다. 그러나 이 사건에서 대법원은 노동관행의 성립과 관련하여 이미 퇴직한 근로자들에게까지 사용자가 임의로 임금인상분 및 퇴직금인상분 차액을 추가 지급하여 준 것은 이미 퇴직한 근로자들과 사용자 사이에 있었던 외부적 사정에 불과하여 노동조합 또는 근로자 집단과 사용자 사이의 노사관행이 성립할 수도 없다고 보았는데, 이는 비판의 여지가 있다고 본다. 왜냐하면 비록 노동조합 또는 근로자 집단과 사용자 사이에 노사관행은 성립하지 않는다고 하더라도 퇴직근로자와 사용자 사이의 노사관행은 성립할 수 있기 때문이다.⁹⁵⁾ 또한 대법원은, 이 사건에서 “단체협약이 퇴직자에게도 적용된다.”는 내용의 노사관행이 성립할 수 있어야 그 청구권이 성립한다고 하였는데, 이는 노동관행의 대상내용에 착오가 있는 것이라 할 수 있다. 노동관행의 대상내용은 “단체협약의 적용” 내용이 아닌 “임금인상분 및 퇴직금인상분 차액의 추가 지급 사실”이 그 내용이 되어야 한다. 그렇게 하면 임금인상분 및 퇴직금인상분 차액의 추가 지급 사실은 퇴직근로자와 사용자 사이에 존재하는 노동관행으로 인정될 수 있는 것이다. 이 사건에서 대법원의 판결과 같이 노사관행이 성립하지 않는다고 하면 퇴직근로자는 노사관행이 아닌 사실인 관습 또는 신뢰책임을 주장함으로써 임금 및 퇴직금인상분 차액을 청구할 수 있다고 본다. 물론 사실인 관습 또는 신뢰책임의 성립요건은 충족되어야 할 것이다.

VI. 나오며

노동관행은 근로자 집단에 관계되는 것일 수도 있고 개별 근로자에 관계되는 것일 수도 있으며 그에 따라 법적 성질이 다를 수 있다고 본다. 근로자 집단에 관계되는 노동관행은 다수 근로자의 근로조건 및 기업의 질서와 관계된 규범으로서 취업규칙과 유사한

95) 퇴직 후 법률관계이어서 노사관행이 아니라고 주장할 수도 있으나 퇴직 시 지급받는 퇴직금이나 체불임금 청산과 같이 이 사건 임금인상분 및 퇴직금인상분 차액의 지급 관행은 노동관계에서 성립한 관행이므로 노사관행이라고 할 수 있다.

성격을 가진다고 하겠으며 개별 근로자에 관계되는 노동관행은 근로계약과 유사한 성격을 가진다고 본다. 노동관행의 성립요건으로 계속성·반복성을 요한다. 관행으로 인정받기 위한 계속성·반복성은 모든 법률행위에 있어서 확일적으로 정해질 수는 없다고 본다. 노동관행은 관습법적 지위 또는 규범적 지위, 계약적 지위, 사실인 관습적 지위에 있을 수도 있고 사실인 관습에 이르지 못한 지위에 있을 수 있다. 우리나라 대법원은 규범과 동등한 정도이거나 사실인 관습과 묵시적 합의를 갖춘 노동관행에 대하여 법적 구속력을 인정하고 있다고 하겠다.

신뢰책임이 성립하기 위해서는 당사자 사이에 특별결합관계가 존재하여야 하며 신뢰의 대상인 법률행위적 표지가 존재해야 하고 귀책성이 있어야 하며, 신뢰자는 선의여야 하고 신뢰와 조치 간에 인과관계가 있어야 한다. 관행은 계속성·반복성과 묵시적 동의의 두 요건을 충족해야 하지만 신뢰책임은 이 두 가지 성립요건 중 한 가지 또는 두 가지 모두를 충족하지 않아도 성립이 가능할 수 있다. 신뢰책임은 노동관행의 성립과 병존할 수 있으나 노동관행이 성립하면 신뢰책임을 원용할 실익이 없어진다. 따라서 노동관행이 규범이나 계약으로서의 법적 지위를 인정받지 못할 때 신뢰책임을 원용할 수 있다고 본다. 신뢰의 크기에 비례한 책임부담의 원칙을 적용한다면 당사자들이 느끼는 권리 대비 책임의 크기 간의 괴리를 줄이고 쌍방의 만족감을 증대시킬 수 있을 것이라고 본다.

〈참고문헌〉

I. 국내문헌

- 곽윤직, 민법총칙, 1989.
- 김유성, 노동법 I, 법문사, 2005.
- 김지형, 근로기준법 해설(개정 5판), 청림출판, 2001.
- 김증한, 민법총칙, 1980.
- 김치선, 노동법강의, 박영사, 1997.
- 김형배, 노동법, 박영사, 2009.
- 박홍규, 노동법론, 삼영사, 1998.
- 송강직 역, 노동법, 삼지원, 1995.
- 이병태, 최신노동법, 중앙경제사, 2002.

이상윤, 노동법, 법문사, 2002.

이영희, 노동법, 법문사, 2001.

이은영, 민법총칙, 박영사, 2005.

이학춘 역, 독일노동법, 한국경영자총협회, 2002.

임종률, 노동법, 박영사, 2013.

하경효, 노동법사례연습, 박영사, 2002.

강상태, “평균임금의 범위와 산정방법”, 1997노동판례비평, 민주사회를 위한 변호사모임(1988).

권오성, “노사관행의 법적 성질에 관한 일고찰”, 변호사 제34집, 서울지방변호사회(2004).

권 혁, “노동관행에 따른 급부청구권의 형성과 소멸”, 노동법학 23호, 한국노동법학회(2006. 12).

김재훈, “근로조건 변경의 법리-불이익변경의 한계를 중심으로”, 박사학위논문, 서울대학교 대학원(1999).

김학동, “신뢰책임과 법률행위이론”, 민사법학 제7권, 한국민사법학회(1988).

박수근, “노동관행의 규범성과 단체협약의 소급적 효력”, 2001노동판례비평, 민주사회를 위한 변호사모임(2002).

이달휴, “노동관행의 성립과 효력”, 재산법연구 제24권 제1호, 한국재산법학회(2007).

이호정, “사실인 관습, 관습법 및 임의규정의 관계”, 고시계 1987년 8월호/통권 제366호(1987. 7).

장재현, “민법상의 신뢰책임”, 법학논고 제16집, 경북대학교 법학연구소(2000).

전형배, “단체협약에 예정된 근속기간을 초과한 기간에 대한 퇴직금 누진율의 판단”, 2001노동판례비평, 민주사회를 위한 변호사모임(2002).

정준영, “민법상의 신뢰책임에 관한 연구”, 박사학위논문, 경남대학교 대학원(2006).

정준영, “신뢰책임의 체계적 구성과 민법상 적용”, 재산법연구 제25권 제2호, 한국재산법학회(2008).

현경대, “노동법의 법원에 대한 일고찰”, 국제화시대의 노동법의 과제/가산 김치선 박사 고회기념논문집(1994).

II. 외국문헌

Canaris, *Die Vertrauenshaftung im deutschen Privatrecht*, München, 1971, S.387ff.

David Lewis, *Convention*, New York: Blackwell, 2002.

Gerald J. Postema, *Coordination and Convention at Foundation of Law*, Legal Studies V.11, 1982.

Jules Coleman, *Incorporationism, Conventionality and the Practical Difference Thesis*, Hart's Postscript, New York: Oxford. Press, 2001.

Seiter, *Die Betriebsübung*, 1967, S.92ff.

Hermann Eichler, *Die Rechtslehre vom Vertrauen*, 1950. S. 3.

山口浩一郎, “労働慣行と破棄”, 季刊労働法 133號, 總合労働研究所(1984).

A Study on Labor Practices and Liability for the Breach of Confidence

Jung, Myung-Hyun, LL. D.*

<Abstract>

Labor practices become an actual rule in the partial society and play important roles in regulating employment conditions when details of a labor contract cannot be defined due to the lack of relevant provisions in a collective agreement, rule of employment and a labor contract, etc.

Labor practices are concerned with either a group of employees or an individual employee. While those related with a group of employees are similar to rules of employment, those related with an individual employee are similar to a labor contract.

The criteria for establishment of labor practices such as continuity, repeatability cannot be defined uniformly. They are varied according to a specific situation. The Supreme Court of Korea acknowledges that a labor practice which is equal to a norm or de facto custom with an implicit consent carries legal binding force.

Though a certain action is not recognized as a labor practice which carries legal binding force, it can still be a basis for liability for the breach of confidence, which also carries legal binding force. Acknowledging liability for the breach of confidence will contribute to an amicable settlement by taking the proportional responsibility.

Key words : Practice, Labor Practice, Liability for the Breach of Confidence, Conventional Law, De Facto Custom.

* Privatdocent, Dept. of Law, Dong-A University